정책자료
2023-07

취업형태 다변화와 노동법상 사용자 개념의 다원적 구성

남궁준

한국노동연구원

목 차

요 약 ····· i

제1장 서 론 ····· 1

제1절 연구의 배경과 필요성 ····· 1

1. 취업형태 다변화의 문제와 '비정규직' 문제 ····· 1
2. 다원적 사용자 개념의 이론화 · 체계화와 그에 근거한 확장성 검토의 필요성 ····· 3

제2절 연구의 목적과 구성 ····· 4

제2장 현행 노동관계법령의 상황과 문제 유형의 재구성 ····· 7

제1절 서 론 ····· 7

제2절 사용자 개념에 대한 현행법의 규율 ····· 7

1. 사용자와 사업주 개념의 정의 현황 ····· 7
2. 사용자 범위를 확대한 개별적 노동관계법령 규정 ····· 11

제3절 노동법상 사용자 개념의 한계선 긋기 ····· 15

1. 일하는 사람 보호를 위한 법률안 발의 ····· 15
2. 노동수요 측 개념 정의 관련 법적 쟁점 ····· 15

제3장 미국의 공동사용자 법리 ····· 21

제1절 개 관 ····· 21

제2절 공동사용자 법리의 전개 ····· 24

1. 「공정근로기준법」의 공동사용자 원칙 ····· 24
2. 「연방노동관계법」의 공동사용자 원칙 ····· 26

제3절 공동사용자 지위에서 고용조건 지휘통제권의 정도 ····· 27
1. 배경과 전개 ····· 27
2. 공동사용자의 유보된 통제권 논의 ····· 34
3. 중개자를 통해 행사한 통제를 포함하는 간접통제 ····· 38
4. 연방노동위원회의 공동사용자 지위 해석 변화 ····· 40
제4절 파견용역 고용관계의 공동사용자 ····· 41
1. 사용사업주/원청의 단체교섭 관련 의무 ····· 41
2. 부당노동행위 책임 ····· 42
제5절 소 결 ····· 43

제4장 요약 및 결론 ····· 44

참고문헌 ····· 49

요 약

노동법의 목적은 흔히 “근로자 보호”로 이해되고 있는데 이를 법적으로 표현하면 근로자에게 노동조건 및 사회보장급여와 관련된 권리, 권한, 혜택(법적 보호 가치가 있는 이익)을 부여한다는 것이다. 그리고 이는 권리에 대응하는 의무를 이행하고, 권한에 조응하는 책임을 부담하며,[1] 혜택을 제공할 상대방의 존재를 전제로 한다. 그렇기에 현행 노동관계법은 사용자를 그러한 의무, 책임, 혜택 제공의 주체로 삼아 근로자 보호를 실현하고 있다.

따라서 전통적 · 표준적 근로자가 아닌 노무제공자에게 여러 노동관계법상 권리 등을 부여한다고 하더라도, 막상 그것을 관철하는 데 있어 실질적으로 가장 중요한 역할을 하는 사용자가 확정되지 않거나, 사용자로 주장되는 이가 그러한 사실을 부인하거나, 최종적으로 문제를 해결해야 하는 법원이 그러한 판단을 할 수 있는 객관적 기준을 갖고 있지 않다면 ‘노동법의 인적 적용범위 확대’의 실익은 전혀 없다고 말할 수 있다. 예컨대 「근로기준법」상 근로자로는 볼 수 없는 ‘특고’, 프리랜서, 플랫폼종사자 등으로 (각각) 조직되어 설립신고까지 마친 노동조합이 다수 존재하나, 그들로부터 단체교섭을 요구받은 이가 사용자임을 부인하여 실제 단체교섭에 이르지 못하는 경우가 빈번히 발생하고 있다.[2]

개별 노동법 규범의 다양한 목적에 따라 노동법 주요 개념의 정의와 범주를 달리 결정하고자 하는 필자의 생각은 이 연구에서도 유효하다. 지난 연구에서 노무제공자가 갖는 총 네 가지 취약성과 두 가지의 속성을 개념화했고 상호관계를 밝혔다. 즉 ① 법적 인격적 종속성(노동력 자

1) “법의 정신은 권한과 책임을 조응시키는 데 있다.”, 박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, p.7.
2) 박은정(2020), 「지금 왜 다시 사용자인가? 플랫폼 노동관계에서 사용자 찾기」, 『노동법포럼』 31, 노동법이론실무학회, pp.215~252.

체를 사용자의 지시 · 처분에 맡겨야 하는 법적 의무로부터 비롯되는 인격적 피지배 또는 민주성 결핍), ② 법적 경제적 종속성(약정한 기간 · 시간 동안 자신의 노동력을 독자적으로 사용해 경제적 이익 창출 금지), ③ 계약 교섭 및 계약 결과의 불공정을 야기하는 경제적 의존성(임노동을 통해 생계를 유지해야 하는 노무제공자의 사회경제 구조적 취약성), ④ 최소한의 인간존엄 및 생존을 위협하는 노동조건을 초래할 수 있는 경제적 의존성을 해소 또는 완화하는 것을 목적으로 하는 개별 법규범의 총합이다.[3] 네 가지 취약성에 더해 "조직적 종속성"(혹은 사업편입성)이라는 속성이 있고, 이는 사용자 측면(해당 노무제공자의 업무가 사용자 사업수행에 핵심적 · 상시적인지)과 노무제공자 측면(해당 업무가 시장에서 독립적으로 거래될 수 있는지, 즉 사업자성 유무)의 두 가지로 구별할 수 있는데, 이것의 존재는 각각 법적 인적 종속성과 경제적 의존성(계약조건의 불공정성)의 존재를 추정 · 징표한다.

이 연구는 이러한 개별적 · 구체적 취약성으로부터 도출되는 개별적 · 구체적 '이익'을 얻는 이가 사용자로서 해당 노동법상 권리에 대응하는 의무를 부담해야 한다는 원칙하에 사용자 개념 및 범위 문제를 접근하고자 한다. 즉 연구책임자의 선행연구가 '취약성' 개념을 분석 · 유형화하고 각 취약성과 개별 노동법 규범을 연계하였다면, 본 연구는 '이익' 개념을 분석 · 유형화하고 이를 박제성(2022) 등의 선행연구에서 검토 · 제안된 '사업' 개념과 연동해,[4] 다양한 맥락에서 등장하는 사용자 해당성, 사용자 범위의 획정, (확정된 사용자가 복수일 경우) 각 사용자에게 귀속되는 의무와 책임의 종류 및 정도의 문제를 판단할 객관적 기준을 개발하는 것을 본 연구와 후속연구의 궁극적 목적으로 삼는다.

다시 말해 본 연구와 후속연구는 다양한 취업형태하에 있는 노무제공자의 권리, 권한, 혜택에 대응하는 의무와 책임을 부담하는 사용자의 개념 · 범주를 분석하고 적용되는 법령과 법률관계의 특성에 따라 해당 '사

3) 남궁준(2021), 『취업형태 다변화와 노동법상 임금원칙의 확장성 검토』, 한국노동연구원 참조.
4) 박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원 참조.

용자'를 확정하고 사용자가 복수일 경우 관련 의무 · 책임의 분담 및 귀속을 결정할 객관적 기준을 개발 · 제안하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 개별 사건에서 구체적으로 타당한 결론을 끌어내기 위한 목적과 수준에서 다루어졌던 사용자성에 대한 판례에 정합적인 논리를 제공하여 예측 가능성과 법적 안정성까지 확보하는 것을 목적으로 한다.

다만 본 연구는 이러한 이론 개발을 위한 전 단계 작업에 주력한다. 우선 본 연구의 문제의식을 명확히 하기 위해 노동관계의 유형을 체계화하는 것이 목적이다. 따라서 우선 먼저 확장된 사용자 범위를 반영하고 있는 현행 노동관계법령의 규정을 살펴본다. 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」은 파견근로자와 관련해 파견사업주에게 전적으로 귀속되었을 사용자의 의무와 책임 중 일부를 사용사업주에게 분배하고 있다. 「산업안전보건법」도 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위해 조치를 취해야 하고, 이와 연계해 산업재해 발생건수 공표에 있어서도 해당 근로자를 포함시킨다. 「근로기준법」도 도급사업에 대한 임금 지급 시 직상 수급인의 귀책사유 존재를 전제로 한 연대책임, 이를 한층 더 확장 · 강화한 건설업에서의 책임, 「최저임금법」은 최저임금액에 미치지 못하는 임금 지급 시 도급인과 수급인의 연대책임을 규율하고 있다.

결국 우리의 개별적 근로관계법 · 노동보호법은 첫째, 법으로 인정한 파견근로관계의 경우에는 포괄적인 차원에서 복수의 사용자 존재를 전제하고 그 안에서 적정하게 사용자 책임을 재분배한다. 둘째, 기본적인 인권에 해당하는 근로자의 신체적 안전 · 건강과 같은 근로조건의 경우 그 확보에 있어 최적의 지위에 있는 주체에게 사용자 책임을 부과한다. 셋째, 위의 두 경우가 아니더라도, 예컨대 파견근로관계도 아니고 주요 근로계약 조건의 하나인 임금에 해당하는 것이라도 그것의 현실적 보장을 위해 꼭 필요한 경우에는 예외적으로 입법을 통해 본래의 사용자를 넘어 그에 대한 책임을 (일부) 귀속시키고 있다는 것을 알 수 있다.

역사적으로 연방노동위원회의 결정과 법원 판결이 공동사용자의 지위 원칙을 형성한 것은 파견 및 용역고용의 단체교섭 관계를 규율하려는 목적이었다. 이번에 개정된 연방행정법규(시행령)가 정한 고용관계

의 핵심사항과 조건은 열거적인 것이 아니라 예시적인 것이다. 연방노동위원회는 공동사용자 지위 판단에서 '핵심적'인 것으로 간주될 수 있는 고용관계의 핵심사항과 조건을 다음의 7개 범주로 나누었다. ① 임금, 부가급여 및 기타 보수, ② 근로시간과 작업일정, ③ 수행될 업무의 배분, ④ 그 업무수행에 대한 감독, ⑤ 업무수행의 방식, 수단 및 방법을 통제하는 작업규칙과 지침, 징계사유, ⑥ 채용과 해고를 포함하여, 고용기간, ⑦ 근로자의 안전과 건강에 관련된 작업조건. 이 범주에 속하는 하나 이상의 사항에 대하여 실제로 행사하진 않았지만 통제권을 유보하고 있거나 중개인을 통하여 간접적으로 통제를 행한 사업주들은 공동사용자 지위가 성립될 것이다. 공동사용자는 자신이 통제권을 보유하고 있거나 통제권을 행사한 고용관계 사항이나 조건(이 경우에는 개정 시행령이 정한 고용관계의 핵심사항이나 조건에 해당하는지는 관계가 없음)에 관하여 그 근로자들의 교섭대표와 단체교섭을 해야 한다.

노동법의 사명을 '이익이 있는 곳에 책임도 있다'는 원칙의 노동관계에서의 실현으로 보는 입장(강희원, 2011)이 폭넓게 받아들여지고 있고,[5] 이를 '사업 네트워크'(강주리, 2022) 등의 개념을 통해 사용자성 논의에서도 현대화하고자 하는 이론적 시도가 있는바,[6] 본 연구는 원칙적으로 이러한 문제의식에 동의하면서도 여기서의 '이익'의 개념을 명확히 정의하고 유형화하여 그 구체적 이익에 비례하는 사용자의 '책임'을 설정하고 부여하는 작업이 필요하다.

일단 사용자 개념을 파악할 때 명확한 출발점은 근로자와 근로계약을 체결한 타방 당사자이다. 이때 '이익'은 순수하게 법적인 이익으로서 사용자가 약정 기간・시간 동안 근로자의 노동력을 자신의 의지에 따라 배타적으로 사용할 수 있는 권한을 획득하는 것을 의미한다. 즉 해당 이익의 구체적・경제적 가치를 검토할 필요 없이 근로계약을 체결하고 지시권을 행사하는 자가 사용자가 된다.

5) 강희원(2011), 「간접고용과 근로자의 보호 : 시민법적 계약형식과 노동법적 이념의 갈등」, 『경희법학』 46 (2), pp.9~64.
6) 강주리(2022), 「사업 네트워크와 사용자 책임」, 『노동법학』 81, 한국노동법학회, pp.1~39.

다음은 경제적 관점에서의 접근인데, 이익 개념을 검토할 때 노동법상 '사업' 개념도 함께 검토되어야 한다. 왜냐하면 해당 이익이 실현되는, 즉 의미 있는 경제적 가치를 창출하는 단위는 원칙적으로 사업, 즉 "하나의 사업목적을 위하여 유기적으로 연결되어 있는 경제적 동일체"로 보는 것이 가장 합리적일 것이기 때문이다.[7] 다만 이 사업의 개념 범주는 해당 사건에 적용될 법령의 목적에 따라 가변적일 수 있어 구체적으로 검토해야 한다. 이러한 작업은 후속연구에 담고자 한다.

7) 박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, p.7.

제 1 장
서 론

제1절 연구의 배경과 필요성

1. 취업형태 다변화의 문제와 ‘비정규직’ 문제

취업형태 다변화의 문제는 종종 비정규직 문제로 치환되곤 한다. 우리가 비정규직 문제를 다룰 때 늘 논쟁이 되는 것은 현재 비정규 고용이 전체 고용에서 얼마를 차지하는지에 관한 것이다. 비정규직 규모와 관련하여 입장에 따라 차이가 존재하는데, 이러한 차이점은 비정규 고용으로 파악하는 대상집단 설정에서 차이가 나기 때문이다. 비정규 고용 형태의 현황을 정확히 파악하기 위해서는 ‘비정규직’ 개념이 먼저 명확하게 정의되어야 한다. 그런데 “비정규직” 혹은 “비정규근로자”라는 말은 법률용어는 아니다. 우리 법제도 그렇고 외국의 입법례에서도 ‘정규직’ 또는 ‘비정규직’의 정의를 실정법에 명시적으로 두고 있는 경우는 찾기 어렵다.

법정화된 개념이 없는 가운데 여러 입장은 각자의 관점에 따라 비정규직 개념을 정의하고 그 기준에 입각해 비정규직의 규모를 추정하여 도출된 상이한 결과를 기반으로 현상을 진단하고 정책을 수립하게 된다. 구체적 원인은 더욱 다양하겠지만 법적 관점에서 보자면 이러한 결과가 나오는 것은, 비정규직을 궁극적으로 형식적 · 소극적인 법적 관점에서 파악할 것인가 아니

면 실질적 · 적극적인 정책적 관점에서 파악할 것인가에 대한 입장 차이에서 비롯된 것이라고 볼 수 있다.[1)]

비정규직과 가장 가까운 법률용어는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 "기간제근로자"와 "단시간근로자", 그리고 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 "파견근로자"이다. 이들은 「근로기준법」상 근로자이며 각각 ("정규직"의 각 요소를 보유하는) 기간의 정함이 없는 근로자, 전일제 근로자, 자신을 고용한 사용자의 지휘 · 감독을 받으며 근로를 제공하는 근로자(직접 고용된 근로자)와 구별된다는 의미에서 비정규직이다(형식적 · 소극적인 법적 관점).

그러나 통계적으로 볼 때 비정규직이라는 용어는 더욱 큰 외연을 갖는다. 사회적으로 더욱 취약한 취업자 집단이라는 뉘앙스도 머금는다(실질적 · 적극적인 정책적 관점). 「경제활동인구조사 근로형태별 부가조사」는 매년 8월에 실시되는데 여기서 공식통계로 집계되는 비정규직은 "한시적 근로자", "시간제 근로자", "비전형 근로자"로 구분된다. 이 중 비전형 근로자는 "파견근로자", "용역근로자", "특수형태근로종사자", "가정 내(재택, 가내) 근로자", "일일(단기)근로자"로 세분된다. 여기서 용역근로자는 용역업체에 고용되어 동 업체에서 지휘 · 감독을 받으며 다른 업체에서 근무하는 근로자를 말한다. 특수형태근로종사자는 "지난 주에 다니던 직장(일)은 개인적으로 고객을 찾거나 맞이하며 서비스를 제공하고 그 일한 만큼(실적에 따라) 소득을 얻는 형태에 해당"되는 취업자로 정의된다.[2)]

이 연구가 관심을 기울이는 취업자 집단은 "특수형태근로종사자"(병행조사가 되고 있는 신종사상지위 기준에 따르면 "의존계약자")[3)]와 "용역근로자"이다. 필자가 시리즈로 연구하고 있는 '취업형태 다변화' 연구의 첫 번째(2021)는 노동법상 임금규범이 「근로기준법」상 근로자가 아닌 취업자에게

---

1) 박종희(2011), 「한국의 비정규고용의 실태와 법률적 쟁점 : 비정규고용의 현황, 대응과정 및 향후 개선방안을 중심으로」, 『외법논집』 35 (4), 한국외국어대학교 법학연구소.

2) 한국노동연구원(2022), 『KLI 비정규직 노동통계』, 한국노동연구원, p.2.

3) 2019년 신종사상지위 도입 시범 조사가 경제활동인구조사 본조사와 함께 병행조사되고 있는 중이다. 통계청, 한국종사상지위분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

도 적용될 수 있는지, 그렇다면 왜 가능한지를 검토했다. 두 번째는 근로시간과 해고 관련 규범의 적용 가능성을 살폈다. 두 연구 모두 취업자 혹은 노무제공자의 측면(노동공급 사이드)에 주목한 연구였다. 이 연구는 노동수요 사이드를 바라보는 연구이다. 어떤 사안의 노동공급자가 근로자가 아니기 때문에 당연히 그의 사용자가 될 수 없는 것처럼 보이는 사람 혹은 단체, 혹은 고용하고 있는 근로자가 있어 사용자이기는 하나 직접 고용하고 있지 않은 근로자(혹은 직접 계약관계를 맺고 있지 않은 非근로자인 취업자)의 사용자로는 보이지 않는 사람 혹은 단체가, 노동법상 사용자에게 부과된 일정한 의무와 책임을 부담해야 하는 경우가 있을 수 있는지, 만약 있다면 언제인지가 이 연구의 질문이다. 후자의 질문이 있기에 "용역근로자"인 비정규직도 이 연구의 범위에 들어오게 된다.

2. 다원적 사용자 개념의 이론화 · 체계화와 그에 근거한 확장성 검토의 필요성

노동법의 목적은 흔히 "근로자 보호"로 이해되고 있는데 이를 법적으로 표현하면 근로자에게 노동조건 및 사회보장급여와 관련된 권리, 권한, 혜택(법적 보호 가치가 있는 이익)을 부여한다는 것이다. 그리고 이는 권리에 대응하는 의무를 이행하고, 권한에 조응하는 책임을 부담하며,[4] 혜택을 제공할 상대방의 존재를 전제로 한다. 그렇기에 현행 노동관계법은 사용자를 그러한 의무, 책임, 혜택 제공의 주체로 삼아 근로자 보호를 실현하고 있다.

따라서 전통적 · 표준적 근로자가 아닌 노무제공자에게 여러 노동관계법상 권리 등을 부여한다고 하더라도, 막상 그것을 관철하는 데 있어 실질적으로 가장 중요한 역할을 하는 사용자가 확정되지 않거나, 사용자로 주장되는 이가 그러한 사실을 부인하거나, 최종적으로 문제를 해결해야 하는 법원이 그러한 판단을 할 수 있는 객관적 기준을 갖고 있지 않다면 '노동법의 인적 적용범위 확대'의 실익은 전혀 없다고 말할 수 있다. 예컨대 「근로기준법」상 근로자로는 볼 수 없는 '특고', 프리랜서, 플랫폼종사자 등으로 (각각)

4) "법의 정신은 권한과 책임을 조응시키는 데 있다.", 박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, p.7.

조직되어 설립신고까지 마친 노동조합이 다수 존재하나, 그들로부터 단체교섭을 요구받은 이가 사용자임을 부인하여 실제 단체교섭에 이르지 못하는 경우가 빈번히 발생하고 있다.[5)]

이러한 문제적 현상에 대해서는 이미 법제도화된 대응으로 미국의 「공정근로기준법(Fair Labor Standards Act : FLSA)」과 「연방노동관계법(National Labor Relations Act : NLRA)」에 따른 '공동사용자 법리(joint-employer doctrine)'가 있고, 법이론 · 법해석론적으로 '동태적 사업 개념'[6)]이나 '기능적 사용자론'[7)]이 유력하게 제시되었으며, 신진연구자에 의해서도 '사업 네트워크와 사용자 책임'[8)] 등이 조명된 바 있다. 이러한 다양한 법리 개발과 연구의 등장은 표준고용관계, 전형적 모범으로서 「근로기준법」상 근로자 개념만으로는 노동법의 목적을 충실히 달성할 수 없는 현실을 반증한다고 할 것이다.

제2절 연구의 목적과 구성

개별 노동법 규범의 다양한 목적에 따라 노동법 주요 개념의 정의와 범주를 달리 결정하고자 하는 필자의 생각은 이 연구에서도 유효하다. 지난 연구에서 노무제공자가 갖는 총 네 가지 취약성과 두 가지의 속성을 개념화했고 상호관계를 밝혔다.[9)] 즉 ① 법적 인적 종속성(노동력 자체를 사용자의 지시 · 처분에 맡겨야 하는 법적 의무로부터 비롯되는 인격적 피지배 또는 민

5) 박은정(2020), 「지금 왜 다시 사용자인가? 플랫폼 노동관계에서 사용자 찾기」, 『노동법포럼』 31, 노동법이론실무학회, pp.215~252
6) 박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, p.3.
7) Jeremias Prassl(2015), *The Concept of the Employer*, Oxford Monographs on Labour Law, Oxford University Press.
8) 강주리(2022), 「사업 네트워크와 사용자 책임」, 『노동법학』 81, 한국노동법학회, pp.1~39.
9) 남궁준(2021), 『취업형태 다변화와 노동법상 임금원칙의 확장성 검토』, 한국노동연구원 참조.

주성 결핍), ② 법적 경제적 종속성(약정한 기간 · 시간 동안 자신의 노동력을 독자적으로 사용해 경제적 이익 창출 금지), ③ 계약 교섭 및 계약 결과의 불공정을 야기하는 경제적 의존성(임노동을 통해 생계를 유지해야 하는 노무제공자의 사회경제 구조적 취약성), ④ 최소한의 인간존엄 및 생존을 위협하는 노동조건을 초래할 수 있는 경제적 의존성을 해소 또는 완화하는 것을 목적으로 하는 개별 법규범의 총합이다.[10] 이 네 가지 취약성에 더해 "조직적 종속성"(혹은 사업편입성)이라는 속성이 있고, 이는 사용자 측면(해당 노무제공자의 업무가 사용자 사업수행에 핵심적 · 상시적인지)과 노무제공자 측면(해당 업무가 시장에서 독립적으로 거래될 수 있는지, 즉 사업자성 유무)의 두 가지로 구별할 수 있는데, 이것의 존재는 각각 법적 인적 종속성과 경제적 의존성(계약조건의 불공정성)의 존재를 추정 · 징표한다.

이 연구는 이러한 개별적 · 구체적 취약성으로부터 도출되는 개별적 · 구체적 '이익'을 얻는 이가 사용자로서 해당 노동법상 권리에 대응하는 의무를 부담해야 한다는 원칙하에 사용자 개념 및 범위 문제에 접근하고자 한다. 즉 연구책임자의 선행연구가 '취약성' 개념을 분석 · 유형화하고 각 취약성과 개별 노동법 규범을 연계하였다면, 본 연구는 '이익' 개념을 분석 · 유형화하고 이를 선행연구에서 검토 · 제안된 '사업' 개념과 연동해, 다양한 맥락에서 등장하는 사용자 해당성, 사용자 범위의 획정, (확정된 사용자가 복수일 경우) 각 사용자에게 귀속되는 의무와 책임의 종류와 정도 문제를 판단할 객관적 기준을 개발하는 것을 본 연구와 후속연구의 궁극적 목적으로 삼는다.

다시 말해 본 연구와 후속연구는 다양한 취업형태하에 있는 노무제공자의 권리, 권한, 혜택에 대응하는 의무와 책임을 부담하는 사용자의 개념 · 범주를 분석하고 적용되는 법령과 법률관계의 특성에 따라 해당 '사용자'를 확정하고 사용자가 복수일 경우 관련 의무 · 책임의 분담 및 귀속을 결정할 객관적 기준을 개발 · 제안하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 개별 사건에서 구체적으로 타당한 결론을 끌어내기 위한 목적과 수준에서 다루어졌던 사용자성에 대한 판례에 정합적인 논리를 제공하여 예측 가능성과 법적 안정성까지 확보하는 것을 목적으로 한다.

---

10) 남궁준(2021), 『취업형태 다변화와 노동법상 임금원칙의 확장성 검토』, 한국노동연구원.

다만 본 연구는 이러한 이론 개발을 위한 전 단계 작업에 주력한다. 우선 본 연구의 문제의식을 명확히 하기 위해 노동관계의 유형을 체계화한다. 이어 현행 실정 노동관계법령상 복수·공동 사용자의 존재를 상정해 각각의 의무와 책임을 부과하는 원리가 이미 구현되어 있는 규정을 검토하여 이 논의의 출발선을 확인한다. 그리고 실정법상으로 공동사용자 법리를 구현하고 있다고 평가할 수 있는 미국의 FLSA와 NLRA상 공동사용자 법리를 분석해 시사점을 얻는다.

제 2 장
현행 노동관계법령의 상황과 문제 유형의 재구성

제1절 서 론

여기서는 먼저 확장된 사용자 범위를 반영하고 있는 실정법 규정을 살피고 이어서 현재 국회에 입법발의되어 있는 법안 중 일하는 사람 보호를 위한 기본법이 사용자에 대응되는 개념의 범주를 어떻게 설정하고 있는지, 그리고 그것과 관련해 본 연구와 맞물려 어떠한 쟁점이 있는지 살펴본다. 이를 통해 논의의 현재 상황을 확인하고 다음에서 볼 미국의 공동사용자 법리 및 이론적 분석작업에서 전제할 공통된 이해의 토대를 닦는다.

제2절 사용자 개념에 대한 현행법의 규율

1. 사용자와 사업주 개념의 정의 현황

입법 기술의 측면에서 해당 법령에서 사용하는 용어의 의미를 명확히 하고자 정의 규정을 두고 있는 것이 일반적이다. 정의 규정은 해당 법령에서 개념상 중요한 용어이거나 일반적인 의미와 다른 의미로 사용되는 용어에

대해 법령 자체에서 그 의미를 명확하게 하는 기능을 담당하는데, 이를 통해 법령 해석상의 논란을 예방하고, 법령의 집행과정에서 발생할 수 있는 분쟁을 방지할 뿐 아니라, 여러 조문에서 자주 사용되는 용어를 미리 하나의 조문에서 설명해 줌으로써 법령문을 간결하게 표현할 수 있게 한다.[11)]

그러나 모든 법령에서 정의 규정을 두고 있는 것은 아니다. 사회통념상 일정한 의미가 있는 용어로서 정의 규정 없이도 그 의미를 충분히 알 수 있는 용어인 경우에는 따로 정의할 필요가 없기 때문이며, 이 경우 용어의 구체적인 의미는 법원의 판례나 소관 부처의 행정해석 등을 통해 구체화된다고 할 수 있다.[12)]

노동관계법령에서도 해당 법령에서 사용하는 용어를 명확히 하고자 정의 규정을 두고 있는 것이 일반적인 것으로 보인다. 본 연구의 주제인 노동법상 사용자 개념에 한정하여 살펴보면, 개별 법령마다 노무를 제공하는 자(가령, 근로자, 노무제공자, 특수형태근로종사자 등)에 상대하는 개념으로 사용자, 사업자, 사업주 등을 사용하고 있는 것으로 파악되는바 이하에서 각각의 용례를 살펴보도록 한다.

가. 사용자

노동관계법령에서 노무를 제공하는 자의 상대 개념으로 “사용자”를 사용하는 것이 일반적인 것으로 보인다. 대표적으로 개별적 근로관계의 기본법인 「근로기준법」은 제2조 제1항 제2호에서 ““사용자”란 사업주 또는 사업경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.”라고 규정하고 있다. 「근로복지기본법」 역시 근로기준법과 동일한 자구로 사용자를 정의하고 있다(제2조 제2호).

한편, 일부 법령에서 「근로기준법」상의 사용자 정의 규정을 준용하고 있는 것이 확인되는바, 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」(제3조 제3호), 「근로자퇴직급여 보장법」(제2조 제2호), 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제3조 제5호, 「최저임금법」 제2조가 그것이다.

---

11) 법제처(2023), 『법령 입안·심사 기준』, 법제처 법제지원총괄과, p.57
12) 법제처(2023), 『법령 입안·심사 기준』, 법제처 법제지원총괄과, p.58

사용자의 개념을 정의하고 있는 다른 법령을 살펴보면 일부 자구의 차이가 있으나 「근로기준법」과 유사한 방식으로 규정하고 있음을 확인할 수 있다. 집단적 노사관계의 기본법인 「노동조합 및 노동관계조정법」은 제2조 제2호에서 ""사용자"라 함은 사업주, 사업의 경영 담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다."라고 규정하고 있고, 「양성평등기본법」은 "사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다."라고 규정하고 있으며, 「여성폭력방지기본법」 제2조 제3호 다목 "사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)…"라고 규정하고 있다.

일부 법령에서는 다른 법령에 비해 범위를 축소하여 정의하고 있는바, 「국민건강보험법」 제3조 제2호와 「국민연금법」 제3조 제2호는 "근로자가 소속되어 있는 사업장의 사업주"로 규정하고 있다.

사용자를 정의하고 있는 개별법령의 내용을 살펴보면, 사용자의 개념적 표지를 설정하는 것이 아니라 사용자에 해당하는 자에 대해 한정적으로 열거하는 방식으로 정의하는 특징을 보이며, 대부분이 「근로기준법」상의 사용자 정의 규정을 준용하거나 자구를 일부 달리하여 유사한 내용을 차용하고 있는 것으로 파악된다.

나. 사업주

노동관계법령에서는 노무를 제공하는 자의 상대 개념으로 "사용자" 외에 "사업주"를 사용하는 경우 역시 많은 것으로 파악된다. 법령에서 일반적으로 확인되는 "사업주"의 정의는 "근로자를 사용하여 사업을 하는 자"(「산업안전보건법」 제2조 제4호, 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제2조 제3호, 「임금채권보장법」 제2조 제2호)이다.

일부 법령에서는 "근로자를 사용하여 사업을 하는 자"에 더하여, 입법 목적에 따라 사업주의 범위를 확대하고 있다. 가령 현재 사업을 행하는(영위하는) 것 외에 사업을 하려는 자(「장애인고용법」 제2조 제4호), 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자(「중대재해처벌법」 제2조 제8호)가 사업주의 범위

를 확장하고 있는 정의 규정의 예이다.

한편 일정한 요건을 부가하는 형식(관계법령에 따라 면허·허가·등록을 요하는 건설근로자법, 분진작업을 행할 것이 요하는 진폐예방법)도 찾아볼 수 있다.

용례	관계법령	내용	규정 형식
사용자	근로기준법	사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자	직접 정의
	근로복지기본법	사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자	직접 정의
	노동조합법	사업주, 사업의 경영 담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자	직접 정의
	양성평등기본법	사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자	직접 정의
	여성폭력방지기본법	사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)	직접 정의
	국민건강보험법	"사용자"란 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 '가. 근로자가 소속되어 있는 사업장의 사업주', '나. 공무원이 소속되어 있는 기관의 장으로서 대통령령으로 정하는 사람', '다. 교직원이 소속되어 있는 사립학교를 설립·운영하는 자'	직접 정의
	국민연금법	해당 근로자가 소속되어 있는 사업장의 사업주	직접 정의
	근로자참여법	근로기준법 준용	준용
	퇴직급여법	근로기준법 준용	준용
	장애인차별금지법	근로기준법 준용	준용
	최저임금법	근로기준법 준용	준용
사업주	산업안전보건법	근로자를 사용하여 사업을 하는 자	직접 정의
	임금채권보장법	근로자를 사용하여 사업을 하는 자	직접 정의
	고령자고용법	근로자를 사용하여 사업을 하는 자	직접 정의

용례	관계법령	내용	규정 형식
사업주	장애인고용법	근로자를 사용하여 사업을 행하거나 하려는 자	직접 정의
	중대재해처벌법	자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자	직접 정의
	진폐예방법	분진작업을 행하는 사업 또는 사업장(이하 "사업"이라 한다)에서 근로자를 사용하는 자	직접 정의
	건설근로자법	근로자를 고용하여 대통령령으로 정하는 건설업을 하는 자로서 관계 법령에 따라 면허·허가·등록 등을 받거나 한 자	직접 정의
	지방세법	지방자치단체에 사업소를 둔 자	직접 정의

2. 사용자 범위를 확대한 개별적 노동관계법령 규정

가. 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」

개별적 노동관계법령에서 명시적으로 법상 사용자책임을, 해당 근로자/노무제공자와 근로계약관계를 맺고 있지 않은 사업주에게 부담하도록 하는 사례가 점차 늘고 있다. 예를 들어 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제34조는 「근로기준법」에 따르면 해당 근로자와 근로계약을 체결한 당사자로서의 사용자, 즉 파견사업주에게 전적으로 귀속되었을 의무와 책임을 사용사업주로 하여금 부담하도록 하거나, 파견사업주와 사용사업주가 연대하여 이행하도록 하거나, 하나의 근로조건(유급휴일, 유급휴가)과 관련된 의무를 둘이 분할하여 부담하도록 규정하고 있다. 이러한 파견법 규정은 근로자에 대한 고용과 사용 주체가 분리된 경우 「근로기준법」상 개별 근로조건이 실질적으로 보장될 수 있는 방안을 입법적으로 마련한 것이라고 할 수 있다. 즉 개별 근로조건의 성질을 감안해 해당 근로조건을 실효적으로 확보해 줄 수 있는 주체에게 그 의무를 부담시킨 것이다.

나. 「산업안전보건법」

「산업안전보건법」도 도급인의 안전조치 및 보건조치를 규율하는 제63조

에서 “도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다. 다만, 보호구 착용 지시 등 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외한다”라고 정하고 있다. 나아가 산업재해 발생건수 등의 공표에 대해 규정하는 동법 제10조 제2항은 고용노동부장관은 도급인의 사업장 중 대통령령으로 정하는 사업장에서 관계수급인 근로자가 작업을 하는 경우에 도급인의 산업재해 발생건수 등에 관계수급인의 산업재해 발생건수 등을 포함하여 공표할 것을 요구하고 있다. 산업안전보건이 갖는 특별한 가치와 중요성, 그리고 해당 물리적 공간을 안전하고 건강하게 일할 수 있는 환경으로 만드는 데 필요한 법적 권리 · 권한과 사실적 지배력이 있다는 점에 근거해 도급인과 직접 근로계약관계를 맺고 있지 않은 사람에게까지 (산업안전보건 관련) 사용자책임을 확장한 것으로 이해할 수 있다.

다. 「근로기준법」과 「최저임금법」

산업안전보건과 같은 특수한 근로조건이 아닌 일반적 근로계약 조건이 파견근로관계와 같은 특수한 간접고용관계가 아닌 일반 하도급관계에서 문제가 된 경우에 대해서도 우리 「근로기준법」은 사용자 범위를 부분적으로 확장하고 있다. 「근로기준법」 제44조(도급사업에 대한 임금 지급)는 “사업이 한 차례 이상의 도급에 따라 행하여지는 경우에 하수급인(下受給人)이 직상(直上)수급인의 귀책사유로 근로자에게 임금을 지급하지 못한 경우에는 그 직상수급인은 그 하수급인과 연대하여 책임을 진다. 다만, 직상수급인의 귀책사유가 그 상위 수급인의 귀책사유에 의하여 발생한 경우에는 그 상위 수급인도 연대하여 책임을 진다”라고 규정하고 있다. 이 규정은 도급사업에 있어 하수급인의 근로자 임금보장을 위하여 직상수급인에게 연대책임을 부과하도록 하는 규정인 바, 1980년 「근로기준법」 개정을 통해 도입되었다.[13] 제정 당시에는 하도급인과 귀책사유가 있는 직상수급인 사이에 대하여만

13) 시행 1980. 12. 31. 법률 제3349호, 1980. 12. 31., 일부개정.

연대책임을 규정하였으나, 2012년 「근로기준법」 개정[14]을 통해 직상수급인의 귀책사유가 그 상위 수급인의 귀책사유에 의해 발생한 경우에는 그 상위 수급인도 연대하여 책임을 지는 것으로 개정되었다.[15]

여러 차례 이루어지는 도급관계에 따라 행해지는 사업은, 대개 하수급인이 도급인이나 직상수급인 내지 상위 수급인에 대한 종속도가 높고 영세하여 근로자에게 임금을 지급하지 못할 위험성이 상대적으로 크다는 점, 그리고 이때 하수급인의 근로자는 상위 수급인이나 도급인의 지시·감독에 복종하는 관계에 있는 경우 또한 적지 않다는 점에서, 법은 하수급인의 근로자들에 대한 임금채권을 보장하기 위해 귀책사유가 있는 직상수급인과 그 상위 수급인의 임금 지급 연대책임을 규정한 것이다.[16] 근로자에 대한 임금 지급의 책임은 사용자에게 있고 제3자에게 전가할 수 없는 것이 원칙이지만, 하수급인에게 고용된 근로자의 임금체불에 대하여는 예외적으로 사용자가 아닌 상위 수급인도 일정한 조건 아래서 책임을 지게 함으로써 근로자의 임금이 안전하게 지급되도록 하려는 입법목적을 갖는다.[17] (동 규정 위반에 대해서는 「근로기준법」 제109조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금에 처하며, 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없다.)

이와 같은 도급관계에서 임금 지급 의무와 관련한 사용자 범위의 확대는 건설업에서의 임금 지급 연대책임으로 강화된다. 「근로기준법」 제44조의2부터 제44조의3이 그것인데 일반적인 도급관계에서는 "직상수급인의 귀책사유"가 근로관계에 대한 책임 주체로서 사업주를 확장시키게 되지만, 건설업의 경우에는 그러한 귀책사유도 요구되지 않는다. 나아가 법 제44조의3은 공사도급이 이루어진 경우로서 직상수급인은 하수급인에게 지급하여야 하는 하도급 대금 채무의 부담 범위에서, 그 하수급인이 사용한 근로자가 청구하면 하수급인이 지급하여야 하는 임금(해당 건설공사에서 발생한 임금으로 한정한다)에 해당하는 금액을 근로자에게 직접 지급하여야 하는 경우

14) 시행 2012. 8. 2. 법률 제11270호, 2012. 2. 1., 일부개정.
15) 노동법실무연구회(2020), 『근로기준법 주해 Ⅲ(제2판)』, 박영사, p.110. 남궁준(2021), 앞의 책, pp.61~62.
16) 위의 책, pp.109~110.
17) 임종률(2018), 『노동법(제16판)』, 박영사, pp.426~427. 남궁준(2021), 앞의 책, p.62.

도 명시 · 열거하고 있다. 위 규정들은 “하수급인이 「건설산업기본법」이나 그 밖의 법률로 등록 등을 한 건설사업자가 아닐 때, 그 직상수급인이 하수급인의 근로자에 대한 임금 지급 책임을 하수급인과 연대하여 같이 지도록 하여, 하도급을 하면서 건설 관련 법령에 따라 등록 등을 한 건설사업자에게 도급을 하지 않고 영세한 미등록 건설사업자에게 도급하고, 그 과정에서 영세한 미등록 건설사업자가 임금을 체불함으로써 건설 일용근로자가 피해를 입는 것을 개선”하기 위한 것으로 설명된다.[18] 건설업 분야에서 하수급인의 임금체불이 심각한 현실을 고려하여 이에 대한 별도의 특례를 규정한 것으로 이해된다.[19] 법 제44조의3은 도급근로자의 임금 보호를 위한 또 다른 제도로서 건설공사의 직상수급인 또는 원수급인이 하수급인 소속 근로자에게 임금을 직접 지급해야 하는 또 다른 경우를 규정한 것으로 법 제44조의2와 마찬가지로 개정 때 신설되었다.[20]

이와 함께 「최저임금법」 제6조 제7항에서도 “도급으로 사업을 행하는 경우 도급인이 책임져야 할 사유로 수급인이 근로자에게 최저임금액에 미치지 못하는 임금을 지급한 경우 도급인은 해당 수급인과 연대(連帶)하여 책임을 진다.”라고 규정하고 있다. 「최저임금법」상 수급인이 도급인과 최저임금에 대한 연대책임을 지는 경우는 (1) 도급인이 도급계약 체결 당시 인건비 단가를 최저임금액에 미치지 못하는 금액으로 결정한 경우와, (2) 도급인이 도급계약 기간 중 인건비 단가를 최저임금액에 미치지 못하는 금액으로 낮춘 경우이다.

결국 우리의 개별적 「근로관계법」 · 「노동보호법」은 첫째, 법으로 인정한 파견근로관계의 경우에는 포괄적인 차원에서 복수의 사용자 존재를 전제하고 그 안에서 적정하게 사용자 책임을 재분배한다. 둘째, 기본적인 인권에 해당하는 근로자의 신체적 안전 · 건강과 같은 근로조건의 경우 그 확보에 있어 최적의 지위에 있는 주체에게 사용자 책임을 부과한다. 셋째, 위의 두 경우가 아니더라도, 예컨대 파견근로관계도 아니고 주요 근로계약조건의 하나인 임금에 해당하는 것이라도 그것의 현실적 보장을 위해 꼭 필요한 경

18) 노동법실무연구회(2020), 『근로기준법 주해 Ⅲ(제2판)』, 박영사, p.114. 남궁준(2021), 앞의 책, p.63.
19) 임종률(2018), 『노동법 제16판』, 박영사, p.428. 남궁준(2021), 앞의 책, p.63.
20) 노동법실무연구회(2020), 앞의 책, 박영사, pp.116~117.

우에는 예외적으로 입법을 통해 본래의 사용자를 넘어 그에 대한 책임을 (일부) 귀속시키고 있는 것이다. 그렇다면 남은 과제는 이러한 예외적 확장을 넘어 일정한 요건하에 사용자 범위의 일반적 내지 포괄적 확장이 가능할지를 검토하는 것이다. 이에 대해서는 이 문제를 실정법으로 접근하고 있는 미국의 「공정근로기준법」상 공동사용자 법리를 간략히 살펴본다.

제3절 노동법상 사용자 개념의 한계선 긋기

1. 일하는 사람 보호를 위한 법률안 발의

새로운 취업형태 종사자의 등장으로 인해 발생·심화되는 노동법의 제도적·실질적 사각지대 문제를 해결하기 위해 「근로기준법」의 "근로자"보다 넓은 "일하는 사람"이라는 새로운 포괄적인 인적 범주를 창설하고, 그에 대응하는 「근로기준법」의 "사용자"보다 넓은 "사업자" 혹은 "노무이용사업자" 개념을 신설한 후 기초적이지만 가장 보편적으로 적용되어야 할 일하는 사람의 권리를 명시·보장하는 기본법이 입법 시도되고 있다.[21][22]

2. 노동수요 측 개념 정의 관련 법적 쟁점

노동법의 작동원리에 대한 그간의 전제는, 「근로기준법」은 "근로자"에게 많은 권리와 보호를 제공하고 있으나, 그 실현은 실제 각 권리·보호에 대응하는 사용자의 의무와 책임을 설정하고 그 이행을 사법(私法, 예: 민사소송)·공법(公法, 예: 노동위원회 구제명령, 과태료, 형벌)상 이행확보 수단을 통해 담보하는 메커니즘을 취한다는 것이다. 따라서 사용자가 누구인지를 특

21) 「일하는 사람의 권리보장에 관한 법률안」(이수진 의원 대표발의, 의안번호: 18266, 2022. 11. 16.), 「일하는 사람의 보호 등에 관한 법률안」(장철민 의원 대표발의, 의안번호: 18363, 2022. 11. 22.)

22) 이러한 법안의 학문적 의의에 대한 분석으로 권오성(2022), 「'일하는 사람을 위한 기본법' 제정의 필요성」, 『노동법학』 81, 한국노동법학회 참조.

정하는 것과 그 사용자가 실제로 그러한 의무 · 책임을 이행할 현실적 능력이 있는지가 중요한 것이며, (민법 고용계약의 경우와 달리) 「근로기준법」은 사용자 정의 규정에 사업주(事業主)를 명시하여,[23] 표준적 · 원칙적 사용자는 업으로 계속적 활동을 하는 주체이다. 따라서 어떤 개인이 일회적으로 누군가를 고용하는 경우에도 적용될 수 있는 민법의 고용계약편과는 구별된다. 이 점이 현대법인 노동법의 '근로계약/근로자' 개념과 근대법인 민법의 '고용계약/노무자' 개념이 구별되는 하나의 지점이다. 전자는 노동관계와 노동시장의 구조적 성격, 자본(생산시설)의 소유 여부에 따른 종속 · 의존 관계의 존재 등을 이미 법 안에 반영하고 있는데 반해, 후자는 이러한 거시적 구조 · 맥락을 내화하고 있지 않기 때문이다.

실제 발의된 법안은 사용자보다 넓은 개념을 모색하고 있는데 이와 관련해 입법정책적 선택사항으로 '사업자'와 '개인' 중 하나를 선택할 수 있을 것으로 보인다(현재 발의된 법안은 전자를 선택했다). 장단점이 있다. (타인의 사업을 위해) 계속적인 업으로서 사업활동을 하는 사업(주)를 상대방으로 한정하게 되면 「근로기준법」처럼 상대방의 의무를 부과하는 방식의 입법기술을 택할 수 있으므로, 상대적으로 책임능력, 지불능력 등이 담보가 되어 일하는 사람 법을 통해 보장하고자 하는 노무제공자의 (더 많은) 권리를 더욱 실효성 있게 보장할 수가 있다. 단, 이 경우 사업활동을 하지 않는 개인은 배제되고 사업주 식별 · 특정의 문제가 필연적으로 발생한다.

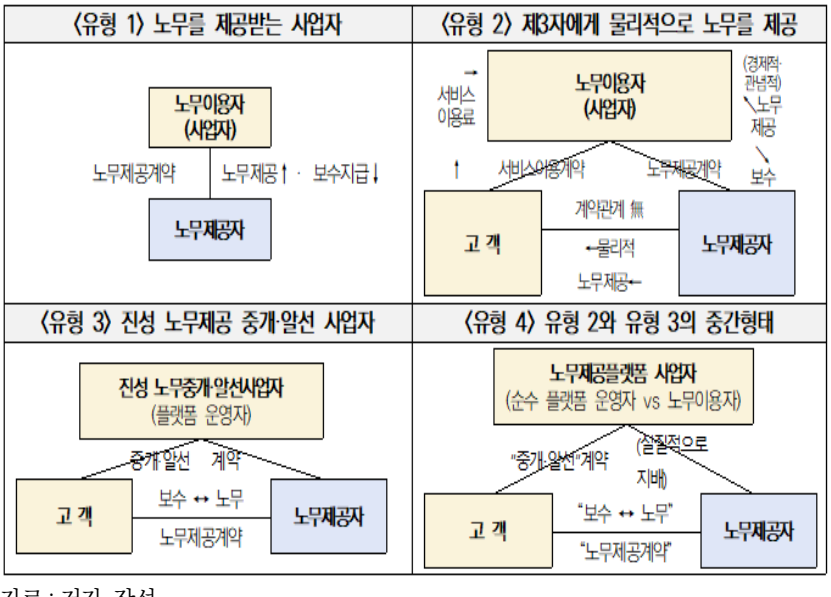
단 (타인을 위해) 과거의 전통적 방식으로도 가능했으나, 최근 각종 디지털 플랫폼의 중개 · 알선을 통해 개인이 타인의 노무제공을 받고 그 대가를 지불하는 경우가 늘어나고 있다고 볼 수 있는데, 사업자가 아닌 개인이 노무제공자로부터 유상으로 서비스를 받은 경우 이때의 개인에게 「일하는 사람 법」이 적용될 수 있는가의 문제가 제기된다. 예컨대 집수리 등 1회성이 아닌 간병 · 돌봄서비스처럼 계속적인 급부를 제공받는 경우가 특히 문제 될 수 있다. 현재 국회에 발의된 「일하는 사람」 법률안'(이수진案 · 장철민案)은 모두 "사업자"라는 용어를 쓰고 법률이 "사업자"의 의무를 규정하는 방식으로 입법이 되어 있음. 즉, 인적 적용범위는 확대, 권리 · 보호 수준은 완화된 '넓고 얕은 「근로기준법」'의 형태를 띠고 있다.

---

23) 「산재보험법」이나 「고용보험법」은 아예 사용자가 아닌 사업주를 수규자로 정함.

노무이용/수령자 측 개념을 입법 정의함에 있어 두 번째 쟁점은 단순 노무 알선·중개 사업자(플랫폼)를 포함할 것인지 제외할 것인지이다. 노무제공(계약) 관계를 도식화하면 아래처럼 유형화가 가능한데, 그중 진정한 노무 중개·알선사업자(노무제공 중개·알선 "플랫폼 운영자" 포함)[24]가 개입한 경우로는 〈유형 3〉이 있다.

[그림 2-1] 노무제공(계약)관계의 유형



자료 : 저자 작성.

24) 「플랫폼 종사자 보호 및 지원 등에 관한 법률안」(장철민 의원 대표발의), 의안번호 8908, 발의연월일 : 2021. 3. 18.
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "온라인 플랫폼"이란 일하는 사람의 노무제공(일의 완성을 위한 경우를 포함한다. 이하 같다)을 중개 또는 알선하기 위한 전자적 정보처리시스템을 말한다.
2. "플랫폼 종사자"란 계약의 명칭이나 형식에 관계없이 온라인 플랫폼을 통해 중개 또는 알선받은 노무를 제공하기 위하여 다른 사람을 사용하지 아니하고 주로 자신의 노무를 제공하고 그 대가로 보수 등을 받는 사람을 말한다.
3. "플랫폼 운영자"란 온라인 플랫폼을 이용하여 플랫폼 종사자의 노무제공을 중개 또는 알선하는 것을 업으로 하는 자를 말한다.
4. "플랫폼 이용 사업자"란 플랫폼 종사자로부터 노무를 제공받고 이를 통해 사업을 영위하는 자를 말한다.

여기서 용어의 명확한 정의가 필요한데, 먼저 "진정 혹은 단순 노무중개·알선사업자"란 노무제공자의 노무제공 그 시기나 방법 등과 관련해 일체 지휘·감독이 없으며(법적, 인적 종속성 결여), 해당 노무/서비스의 가격이나 조건 등에 대해 아무런 통제·지배력을 행사하지 않으면서 오직 노무이용자와 노무제공자의 매칭 서비스만을 수행하는 사업자를 뜻한다.

「일하는 사람 법」이 법적 견지에서 양자 관계에 해당하는 〈유형 1〉과 〈유형 2〉의 노무이용자에게 적용되는 것은 쉽게 납득할 수 있다. 〈유형 2〉의 경우 표면적으로는 고객을 포함해 세 당사자 관계가 존재하는 것처럼 보인다. 그러나 이 노동관계에서 고객은 노무제공자로부터 해당 서비스/노무를 물리적으로 혹은 사실상 수령하는 제3자에 불과하므로(고객과 노무제공자 사이에는 아무런 계약관계가 없음) 〈유형 2〉는 법적으로 노무제공자와 노무이용자의 양자관계이다.

그에 비해 〈유형 3〉의 진성 노무중개·알선사업자(단순 노무중개플랫폼 포함)에게 본 「일하는 사람 법」을 적용하는 문제는 법적·정책적 쟁점이 된다. 일단 이 유형에서 계약관계는 3개가 존재한다(즉 2개가 아님). ① 진성 노무중개·알선사업자와 노무제공자(구직자) 사이의 직업정보 제공, 직업소개, 또는 근로자 공급과 관련된 계약, ② 진성 노무중개·알선사업자와 고객(구인자) 사이의 직업정보 제공, 직업소개, 또는 근로자 공급과 관련된 계약, ③ 고객(구인자)과 노무제공자(구직자) 사이에 고용계약 또는 기타 노무제공계약이 존재한다. 그런데 이러한 법률관계에 대해서는 이미 「직업안정법」이 적용되고 있다.[25]

「직업안정법」은 본래 「근로기준법」에서 금지된 '중간착취'를 예외적으로

25) 「직업안정법」 전부개정법률안(장철민 의원 대표발의, 의안번호 8909, 2021. 3. 18.)은 현행 「직업안정법」을 전부개정하면서 제41조와 제42조에서 "노무중개·제공 플랫폼" 사업자('자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 자신이 직접 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 일정한 대가를 얻는 계약 체결을 위하여 그 계약 정보를 제공하거나 계약 체결을 중개하는 정보처리능력을 가진 전자적 장치 또는 체계를 운영하여 사업을 하려는 자)에 대한 특례를 규정하며 그들의 정보 신고 의무 및 운영 시 준수 사항을 정하고 있다. 다만 그러한 의무는 「직업안정법」 아래에서 허용된 사업을 하기 위해 필요한 공법상 의무를 말하는 것이며 노무제공자와의 관계에서 노무제공자의 노동조건에 대한 권리에 대응하는 사법상 의무를 규정하는 것은 아니다.

허용하는 법이기 때문에, 기본적으로 3자 이상의 다면적 노동관계를 규율의 전제로 한다(단 파견근로관계는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」이 적용). 즉 「직업안정법」은 '직업을 구하는 자'(구직자)와 '노동을 필요로 하는 자'(구인자) 사이의 고용관계를 매개하는 중개인과 매개 행위에 관한 규범이다. 「근로기준법」 제9조는 "누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못하"도록 정하고 있다. 동 조항에서 말하는 예외적으로 취업에 대한 중간인의 개입을 허용하는 대표적인 법률이 바로 「직업안정법」이다. 따라서 「직업안정법」상의 고용관계 매개인은 중간착취의 위험에도 불구하고 '근로자의 직업안정 도모'와 '국민경제의 균형 있는 발전'을 위하여 노동시장에 '허용된 중간자'로서 참여하게 된다.[26]

현재 활동 중인 노무중개 · 제공 플랫폼 사업자는 많은 경우 「직업안정법」의 (형식적으로) "유료직업소개사업"으로 등록되어 있으나 이들이 모두 〈유형 3〉의 진성 노무제공 중개 · 알선사업자에 해당할지, 〈유형 4〉의 노무제공플랫폼 사업자(유형 2와 3의 중간형태)로 보아야 할지는 사건별(case by case)로 따져 검토할 쟁점이다.

다만 「직업안정법」은 공법(公法)이고 「일하는 사람 법」(적어도 노무이용자와 노무제공자 간 노동조건을 규율하는 법률규정만큼)은 사법(私法)이므로, 「직업안정법」의 규율 여부가 곧 「일하는 사람 법」의 규율 여부를 결정하는 것은 아니다. 오히려 「일하는 사람 법」의 적용 여부는 "노무이용자", 즉 "노무제공자의 노무제공을 통해 사업을 영위하는 자"에게 노무제공자를 상대로 일정한/최소 한도의 私法상 의무 · 책임을 부과하는 것이 정당할 만큼, 노무이용자가 해당 노무 자체를 지배하여 자기 사업의 구성요소로 삼았는지를 기준으로 판단해야 한다(예: 노무이용자가 노무제공자에 의해 제공되는 노동/서비스의 가격 조건 결정, 노무의 내용 또는 제공 방식의 결정에 대한 상당한 영향력을 행사한 경우 등으로 단순 노무알선 · 중개로 보기 어려울 정도로 개입하는 경우를 말함). 결국 〈유형 3〉의 진성 노무제공 중개 · 알선 사업자에게 노무제공자에 대한 그러한 사법상 의무 · 책임을 부담토록

26) 김주병(2019), 「직업안정법」을 통한 플랫폼노동중개의 규율 가능성과 과제」, 『노동법학』 70, 한국노동법학회, pp.8~9.

하는 것은 부당하다고 할 수 있다.

그러나 〈유형 2〉와 〈유형 3〉의 중간형태인 〈유형 4〉의 노무제공플랫폼 사업자의 경우 위의 판단기준, 즉 노무제공플랫폼 사업자가 노무이용자로서 해당 노무 자체를 완전히는 아니더라도 상당한 정도로 지배하여 자기 사업의 구성요소로 삼고 있다면 「일하는 사람 법」이 (적어도 일부) 적용되는 것이 부당하지 않을 것이다. 현재 발의된 법률안 중 이수진 의원 대표발의안은 〈유형 3〉을 제외하고 장철민 의원 대표발의안은 포괄하는 것으로 보인다. 종합하면, 「근로기준법」상 사용자에게 대응하는 「일하는 사람 법」상 의무부담 주체의 범위를 적정하게 선택하고 그러한 선택이 잘 구현될 수 있는 적확한 법문을 정의 규정에 마련하는 것이 필요하다.

발의된 법안의 입장을 비교해 보면 :

- (협의) "사업자"(이수진 의원안) : "사업자"란 일하는 사람으로부터 노무를 제공받아 사업을 하는 자를 말한다.[27]
  - ➡ 1안 : 유형 1, 2, 4(중 사실상 2에 해당하는 것)의 노무이용자/사업자 포섭
- (중간) "사업자"/"노무이용자"라 함은 노무제공자의 노무제공을 통해 사업을 영위하는 자를 말한다.
  - ➡ 3안 : 유형 1, 2, 4의 노무이용자/사업자 포섭. 노무의 단순 중개알선은 제외하지만 (협의)에 비해 더 다양한 성격의 〈유형 4〉를 포섭 가능
- (광의) "사업자"(장철민 의원안) : "사업자"란 일하는 사람으로부터 노무를 제공받아 사업을 하거나, 제3자의 사업에 일하는 사람을 제공 또는 소개하는 자를 말한다. [단순 노무제공 중개 · 알선 사업자도 포함]
  - ➡ 2안 : 유형 1, 2, 3, 4 모두의 노무이용자/사업자 포섭

---

27) "노무를 제공받는다" 또는 "노무를 수령한다"는 표현은 물리적인 경우와 경제적 · 관념적인 경우로 나누어질 수 있는데, 백화점 직원(근로자)을 예로 들어보면 백화점 고객이 해당 직원의 제품 안내 및 착장 보조 서비스/근로/노무를 물리적으로 제공받고 또 물리적으로 수령하지만 해당 매장을 운영하는 사업주가 해당 직원(근로자)의 서비스/근로/노무를 경제적 · 관념적으로 제공받고 또 수령하는 것이다. 따라서 해당 사업을 누가 영위하는지, 노무를 공급하는 이가 근로자 또는 노무제공자인지 아니면 자신의 사업을 하는 진성 자영업자인지에 따라 경제적 · 관념적 노무수령 주체가 달라진다.

제 3 장
미국의 공동사용자 법리[28)]

제1절 개 관

간접고용 문제 혹은 복수 사용자 문제에 대한 미국 노동법의 주요 해법은 공동사용자 법리인데, 그 시작은 「공정근로기준법(Fair Labor Standards Act of 1938)」이었다.[29)] 공동고용의 개념은, 「공정근로기준법」의 할증임금 규정에 관한 행정해석에서 처음 나타나기 시작하였는데, 1939년 근로자가 법정근로시간을 초과한 경우에 발생하는 할증임금을 복수의 기업이 연대하여 책임을 지도록 하기 위해 '공동고용' 개념을 창안하였다. 이후 1958년 미국 연방노동부(Department of Labor)의 임금·근로시간국은 「연방행정법규(Code of Federal Regulation : C.F.R.)」를 개정하며,[30)] 「공정근로기준법」상 공동사용자의 지위를 결정하기 위한 공식적인 해석을 규정하고 공포하였다.[31)]

이 「연방행정법규」는 초기 공동고용의 개념과 함께 공동사용자에 관한

---

28) 본 장은 김미영 박사(경기대학교 법학연구소)가 작성한 자문보고서에 기반해 작성하였다.
29) 19 U.S.C. Chapter 8 Fair Labor Standards, §§201-219.
30) 우리의 대통령령(시행령)과 부령(시행규칙)을 합친 것에 비견될 수 있으며, 의회에서 제정한 법률을 집행하기 위해 필요한 해당 법률의 실체적 내용을 구체화하기 위한 (소관 행정부의) 해석 및 절차적 사항을 담고 있다.
31) 29 C.F.R. §791.

개념을 규정하였는데, 이 규정의 핵심은, 복수의 자가 근로자의 고용에 있어 '완전히 분리되지 않은' 경우,[32] 그 근로자의 공동사용자로 간주될 수 있다는 것이었다.[33] 이 기준은 문제가 되고 있는 두 개의 고용이 서로 '완전히 분리되어' 있는지 여부를 고려한다.[34] 동 「연방행정법규」는 공동고용관계가 존재하는지 여부를 확인하기 위한 요소들을 아래와 같이 제시한다.

ⅰ. 사용자들 사이에 근로자들의 서비스를 공유하기로 약정한 경우(예컨대, 근로자 교환); 혹은
ⅱ. 한 사용자가 근로자와 관련하여 다른 사용자(혹은 사용자들)의 이익을 위하여 직접적 혹은 간접적으로 행동하는 경우; 또는
ⅲ. 사용자들이 특정 근로자의 고용과 관련하여 완전하게 분리되어 있지 않아, 한 사용자가 지배하고, 지배당하거나, 다른 사용자와 공통 지배하에 있다는 사실을 이유로, 직접적 혹은 간접적으로, 근로자에 대한 지배를 공유하는 경우

「연방행정법규」에서 노동부는 할증임금 규정의 취지상 공동고용의 결정에서 중요하게 고려하여야 하는 사항은 노무제공자가 어느 사용자의 근로자에 해당하는지가 아니라, 복수의 사용자들이 공동으로 자신의 이익을 목적으로 근로자를 고용하였는지 여부이므로, '공동고용(joint employment)' 여부의 판단기준으로 '지휘감독의 공유(common control)'가 강조되었다.[35] 지난 2016년 오바마 정부하에서, 미국 노동부는 「공정근로기준법」과 「이민자와 계절적 농업 노동자 보호법(Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act)」상 공동사용자 지위를 판단하기 위해 광범위한 '경제적 현실(economic realities)' 기준을 채택한 행정해석을 발표하였는데,[36] 이 행정해석은 "일반적 고용과 마찬가지로 공동고용도 광범위하게 정의되어야 한다"고 제시하였다. 따라서 수직적 공동고용(예: 파견근로, 용역근로 등)의

32) 29 C.F.R. §791.
33) 강주리(2019), 「미국 공정근로기준법의 제3자 규제구조」, 『사회법연구』 39, 한국사회법학회, pp.308~309.
34) 29 C.F.R. §791.2(a).
35) 강주리(2019), 앞의 책, pp.308~309.
36) U.S. Department of Labor, Administrator's Interpretation No. 2016-1(Issued by Administrator David Weil).

경우 공동사용자성을 판단할 때 종래의 지휘·감독에 초점을 맞춘 분석이 아닌 경제적 현실 요소를 검토하여야 한다고 제시하였다.

그러나 지난 2019년 4월 트럼프 행정부에서 공동사용자 법리에 대한 「연방행정법규」가 다시 개정되었는데, 개정된 규정은 경제적 현실 분석을 거의 전적으로 배척했으며, 기존에는 공동사용자성을 추정하는 데 기여할 수 있는 요소들의 일부를 예로 들며 그러한 요소들로 인해 공동사용자성이 더 인정되거나 부정되지 않는다는 문언을 도입했다. 개정 규정은 공동사용자성이 인정되는 상황을 크게 둘로 나누었는데, ① 하나는 근로자가 사용자를 위하여 1주 근로시간 동안, 일정 근로시간 일을 함에 있어, 그 일이 동시에 다른 자에게도 이익을 주는 경우이고, ② 다른 하나는 근로자가 1주 근로시간 동안, 복수의 사용자들을 위해 각각 일을 하는 경우이다.

기존의 「연방행정법규」의 공동사용자 규정은 '완전히 분리되지 않은'이 무엇을 의미하는지 적절하게 설명하고 있지 않다는 점이 지적되어, 노동부는 개정 「연방행정법규」에서 '완전히 분리되지 않은'이라는 표현을 없애고, 이를 다른 자(즉, 잠재적인 공동 사용자)와 관계없이 평가하는, Bonnette v. California Health & Welfare Agency 판결의 4요소 기준, 즉 "ⅰ. 근로자를 고용하거나, 해고한다, ⅱ. 근로자의 작업 일정이나 고용조건을 감독 지배한다, ⅲ. 근로자의 요금 및 지급 방법을 결정한다, ⅳ.근로자의 고용기록을 유지한다"로 대체하였는데, 이 기준은 공동사용자가 실제로 그 권한을 행사하는지 여부에 초점을 맞추고 있다.

이러한 변경된 법리는 지금 현재는 적용되지 않고 있다. FLSA든 NLRA든 공동사용자 법리는 정권에 따라 그 구체적 판단기준이 큰 진폭으로 '좌우 진자 운동'을 해왔기에 지금의 폐지 상태도 사실은 그렇게 놀라운 일이 아니며 언제든 다시 부활할 가능성을 가지고 있다. 따라서 현재 발효 중인지 자체는 큰 의미가 없고 해당 내용이 법리적으로 설득력이 있는지 특히 미국 내가 아닌 타국에서 수용할 만큼 큰 타당성을 가지고 있는지가 오히려 더 중요하다고 할 것이다. 다만 이 장에서는 최근 큰 개정을 겪은 미국 단체교섭제도에서 공동사용자 지위 원칙의 내용과 변화에 대해 좀 더 집중하며 관련이 되는 곳에 한해 FLSA 법리를 함께 살펴보도록 한다.

제2절 공동사용자 법리의 전개

1. 「공정근로기준법」의 공동사용자 원칙

공동사용자 원칙은 1940년대 「사회보장법」과 「공정근로기준법」에서 먼저 형성되었다. 한 명의 근로자에 대하여 공법상의 책임을 지는 둘 이상의 법정 사용자(staturory employer)가 존재할 수 있다는 전제가 있는 것이다. 연방노동부는 1958년 시행령에서 공동고용관계 결정 기준을 명시하였다. 그 기준은 매우 포괄적인 기준을 정하고 있어서 공동고용관계의 범위가 상당히 넓게 해석되었다. 이는 2019년에 트럼프 정부에서 개정되기 전까지 계속 유지되었다.

2019년 시행령은 「공정근로기준법」상 공동고용 관계로 결정될 수 있는 기준을 현저하게 좁혔다. 기존 공동고용관계 결정 기준의 포괄성을 제한하기 위하여 공동사용자 지위 판단의 구체적 지표를 명시하였다. 그에 따르면, 먼저 사용자들이 근로자를 채용하거나 해고하는지, 근로자 고용관계의 조건 또는 근무 일정을 감독하고 통제하는지, 임금 지급의 방법과 수준을 결정하는지, 그리고 근로자의 고용관계 기록을 보관하는지를 포함한 네 가지이다.[37] 그러나 연방법원은 그와 같은 시행령이 모법인 「공정근로기준법」의 목적과 제3조(g)의 명시적 규정에 반한다는 이유로 무효로 판결하였다.[38]

바이든 정부는 노동정책을 트럼프 정부 이전으로 되돌린다는 목표하에 여러 노동법 시행령 개정을 진행하고 있다. 그에 따라 2021년 7월 9일자 관보에 「공정근로기준법」의 공동사용자 판단 지표에 대한 2019년 시행령을 폐지한다는 공고를 게재하였다.[39] 아직까지 새로운 개정안은 공표되지 않은 상태지만 2019년 개정 이전 시행령의 내용이 기반이 될 것은 분명해 보

---

37) https://www.federalregister.gov/documents/2020/01/16/2019-28343/joint-employer-status-under-the-fair-labor-standards-act

38) New York v. Scalia, 490 F. Supp. 3d 748 (S.D.N.Y. 2020).

39) Rescission of Joint Employer Status Under the Fair Labor Standards Act Rule (https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/12/2021-04867/rescission-of-joint-employer-status-under-the-fair-labor-standards-act-rule).

인다. 참고로 2019년 이전 공동사용자 원칙의 「공정근로기준법 시행령」 내용은 다음과 같다.

29 C.F.R § 791.2 공동고용
(Joint Employment Relationship under FLSA of 1938)

(a) 「공정근로기준법(1938)」하에서 개인은 둘 이상의 사용자에 대하여 동시에 근로자 지위에 있을 수 있다. 본 법률은 한 사용자에게 고용된 개인이 동시에 다른 사용자와 고용관계에 있는 것을 금지하지 않는다. 복수의 사용자에 의한 고용관계가 본 법률의 목적에 따른 공동고용인지 아니면 별개의 독립된 고용인지의 결정은 특정 사건에서 나타난 사실 판단에 따른다. 모든 관련 사실들이 둘 이상의 사용자들이 서로 완전히 독립적으로 행위하였고, 둘 이상의 사용자를 위하여 동일한 근로일 동안(during the same workweek)에 노무를 수행한 특정 근로자의 근로조건에 관하여 완전히 분리되어 있음을 보여준다면, 본 법률에 따른 사용자 책임을 결정하는 데 있어서 각 사용자는 근로자가 다른 사용자(들)을 위하여 수행한 모든 노무를 배제할 수 있다.[40] 반대로, 관련 사실들이 둘 이상의 사용자가 그 근로자를 고용한 것이, 예를 들어, 한 사용자의 고용관계가 다른 사용자(들)의 고용관계와 완전히 분리되어 있지 않다는 것을 보여준다면, 동일한 근로일 동안에 공동사용자(the joint employer) 모두를 위한 근로자의 모든 노무는 본 법률에 따른 하나의 고용관계로 간주된다. 그 경우에, 모든 공동사용자들은 특정 근로일 동안 전체 고용관계에 관하여, 연장근로 조항을 포함하여, 본 법률의 적용 가능한 모든 조항을 준수하는 데 있어서, 개별적으로 그리고 연대하여, 책임을 진다.[41] 공동책임을 면하는 데 있어서, 각 사용자는 다른 공동사용자 또는 사용자들이 근로자에게 행한 모든 지급에 대하여 최저임금과 연장근로(수당) 의무가 면책될 수 있다.

(b) 근로자가 수행하는 노무가 둘 이상의 사용자에게 동시에 이익이 되거나, 근로일 기간 내 다른 시간에 둘 이상의 사용자를 위하여 근로하는 것인 경우에, 다음과 같은 경우에 일반적인 공동고용관계(joint employment relationship)가 존재한다고 간주될 것이다.

예를 들어,

(1) 근로자 상호교환 같이, 근로자의 노무를 공유하기 위한 합의가 사용자들 사이에 있는 경우[42] 또는
(2) 근로자와의 관계에서 한 사용자가 다른 사용자 또는 사용자들의 이익을 위하여 직접적 또는 간접적으로 행위하는 경우[43] 또는
(3) 한 사용자가 다른 사용자에 의해 통제되거나 또는 공동 지휘하에 있기 때문에, 사용자들이 특정 근로자의 고용관계에 관하여 완전히 분리되지 않고 근로자에 대한 지휘권을 공유하는 것으로 간주될 수 있는 경우[44]
[23 FR 5905, Aug. 5, 1958, as amended at 26 FR 7732, Aug. 18, 1961].

2. 「연방노동관계법」의 공동사용자 원칙

이번 개정이유서에서 자세히 밝혔듯이, 역사적으로 연방노동위원회 결정과 법원 판결이 공동사용자 지위 원칙을 형성한 것은 파견 및 용역고용의 단체교섭 관계를 규율하려는 목적이었다. 개정이유서에서 인용하고 있는 여러 결정이나 판례들은 공동사용자 지위가 주요 쟁점이 되는 선판례들이다. 가장 먼저 인용되는 1965년 Greyhound 결정과 1966년 제5항소법원 판례도 당연히 용역고용관계(contract employment)에서 단체교섭의무 주체를 다룬 것이었다.[45] 사실관계를 간략히 정리하면, 고용사업주가 공급한 청소미화 근로자들이 사용사업자(Greyhound)의 사업장에서 근로하였고 노동조합이 사용사업자를 상대로 단체교섭을 요구하였으나 그 사업자가 거부한 사례였다. 이 판례가 중요한 것은 용역근로자들이 사용사업자의 사업장 내에서 근로한다는 사실 자체로 공동사용자 지위를 인정하였다는 것이다. 실제로 노무지휘 또는 지휘통제권을 행사하였는지는 판단하지 않았다. 이러

---

40) Walling v. Friend, et al., 156 F. 2d 429(C. A. 8).

41) 법률 제3조(d)('사용자'는 근로자에 관하여 사용자 또는 그 이익을 위하여 직접적으로 또는 간접적으론 행위하는 자를 포함)와 법률 제2조(입법목적)는 근로자의 사용자 수와 관계없이, 근로자는 제7조에 명시한 근로시간을 초과한 시간에 대하여 연장근로수당을 지급받아야 한다고 규정한다. 물론, 근로자가 별개로 구한 추가적인 고용관계에 대해서는 사용자가 책임지지 않는다. 그러나 둘 이상 사용자들이 '공동사용자' 지위에 있는 경우 그리고 근로자가 제7조(a)가 정한 근로시간을 초과하여 근로하도록 허용하거나 요구한 경우에는, 법률 문언과 정신은 모두 연장근로수당의 지급을 요구한다.

42) Mid-Continent Pipeline Co., et al. v. Hargrave, 129 F. 2d 655(C.A. 10); Slover v. Wathen, 140 F. 2d 258(C.A. 4); Mitchell v. Bowman, 131 F. Supp., 520(M.D. Ala. 1954); Mitchell v. Thompson Materials & Construction Co., et al., 27 Labor Cases Para. 68, 888; 12 WH Cases 367(S.D. Calif. 1954).

43) Section 3(d) of the Act; Greenberg v. Arsenal Building Corp., et al., 144 F. 2d 292(C.A. 2).

44) Dolan v. Day & Zimmerman, Inc., et al., 65 F. Supp. 923(D. Mass. 1946); McComb v. Midwest Rust Proof Co., et al., 16 Labor Cases Para. 64, 927; 8 WH Cases 460(E.D. Mo. 1948); Durkin v. Waldron., et al., 130 F. Supp., 501(W.D. La. 1955). See also Wabash Radio Corp. v. Walling, 162 F. 2d 391(C.A. 6).

45) NLRB v. Greyhound Corp., 368 F.2d 778(5th Cir. 1966) on remand from Boire v. Greyhound Corp., 376 U.S. 473(1964).

한 해석은 1982년 Browning Ferris 결정이 있기 전까지 연방노동위원회 결정에서 계속 유지되었다.

사실, 공동사용자 원칙(joint employer rule)은 오랫동안 연방노동위원회 판정에서 적용되어 왔고, 단지, 공동사용자 지위 성립의 기준을 둘러싼 논쟁이 사안별로 엎치락뒤치락하는 경향을 보였을 뿐이다. 트럼프 정부 시기인 2020년에 처음으로 공동사용자 지위 판단 기준을 시행령(code of federal regulations)으로 명시하게 되었다. 그러나 공동사용자 기준을 명시한 시행령이 논쟁을 종식시키지는 못했다. 오히려 당사자의 권리와 의무에 영향이 있는 실체적 사항은 가능한 시행령으로 제정하지 않는다는 연방노동위원회의 오랜 전통을 깼다는 불신만 키웠다. 어쨌든 2020년 시행령은 공동사용자 지위 판단을 둘러싼 논쟁을 사안별로 결정하는 심판절차(adjudication)에서 장래의 사안에 포괄적으로 적용되는 시행령 규정으로 이동시킨 것은 분명했다.

제3절 공동사용자 지위에서 고용조건 지휘통제권의 정도

1. 배경과 전개

1982년 Browning Ferris(Penn.) 결정의 핵심은 공동사용자 지위를 판단할 때, 해당 근로자들 고용관계의 핵심사항과 조건의 전부 또는 일부에 대해 모든 사용자들이 직접적이고 실질적인 통제권을 갖고 있는지, 그리고 그 통제권을 행사했는지 여부를 평가해야 한다는 것이다.[46] 이 사안의 사실관계를 보면, 도급사(Brownining Ferris)는 여러 수급사와 화물운송 도급계약을 체결하고 있었다. 일부 화물트럭 기사(drivers)들이 단체행동에 참여하자 도급사는 그 기사들의 사용자인 수급사들과 계약을 해지하거나 운송물량을 크게 감축하였다. 그러자 수급사인 사용자가 해당 근로자들을 해고한 사례이

46) Browning Ferris Indus.(Penn.), 259 NLRB 60(1981); NLRB v. Browning Ferris Industries, 691 F.2d 1117(3rd Cir. 1982).

다. 이후로 '실질적인 지휘통제권 보유와 직접적인 행사'라는 판단 기준을 적용한 주요 결정이 이어졌다.[47]

그러나 레이건 정부가 끝난 이후 1990년대부터 공동사용자 지위가 쟁점인 사안들에서 연방노동위원회의 심판위원회는 그 판단기준을 엄격히 적용하지 않고 특히 실질적으로 행사되었는지를 평가하지 않는 등 유연하게 해석하는 경향이 일반적이었다. 공화당 정부인지 아니면 민주당 정부인지에 따라 심판의 경향은 부침이 있었으나, 부시 정부를 거치면서도 이를 시행령으로 제정하여 장래의 사안에 대해서 일률적으로 그 원칙을 적용하려는 시도는 없었다.

2015년 Browning Ferris(Cal.) 결정은 공동사용자 지위에 대한 논란에 새로운 국면을 열었다.[48] 사실관계를 보면, 재활용 분류 사업자인 Browning Ferris사는 근로자 파견 기업으로부터 240명의 근로자를 공급받았다. 재활용품 분류 컨베이어 시설에서 이들 파견근로자들은 Brwoning Ferris사의 직접고용 근로자 60명과 함께 동일한 작업을 수행하였다. 파견근로자 240명은 노동조합 조합원이었는데 이후 직접고용 근로자 60명도 같은 노동조합에 가입하였다. 이에 따라 노동조합은 사용사업주인 Brwoning Ferris사와 근로자 파견 기업을 단체교섭 관계에서 공동사용자 지위에 있다고 하였다.

그에 대한 주요 결정은 우선, 사용자들이 해당 근로자 고용관계의 핵심사항과 조건의 전부 또는 일부를 통제한다는 것은 그 방법이 직접적이든 간접적이든 상관없다고 하였다. 즉, 사용사업주가 파견 및 용역사를 통해서 근로자의 노무를 제공받는 경우도 포함되는 것이다. 다음으로, 가장 논란이 되는 내용은 사용자들 사이에 어떠한 계약(파견고용이든 용역고용이든)으로 근로자의 고용관계 내용과 조건에 포함되는 사항에 대한 지휘감독 권한을 정하고 있는 경우, 즉 '유보된 통제권(reserved right of control)' 도 주요 판단기준이라는 부분이다. 나아가 공동사용자로 추정되는 사업자가 그 유보된 통제권을 실제로 행사하였는지 여부는 판단할 필요가 없다고 한 것이다. 이

---

47) Laerco Transp. & Warehouse, 269 NLRB 324(1984); TLI, Inc., 271 NLRB 798 (1984); TLI., Inc. v. NLRB, 772 F.2d 896(3d Cir. 1985).

48) Browning Ferris Indus. of Cal., Inc., 362 NLRB 186(2015); Browning Ferris Indus. of Cal. Inc. v. NLRB, 911 F.3d 1195(D.C. 2018).

러한 결정은 1982년 Browning Ferris(Penn.) 결정과 정확히 상반되는 해석이다. 이와 같이 동일하거나 유사한 쟁점에 대하여 완전히 상반되는 해석론과 결정이 나오는 사례는 흔한 경우이고 새로운 것은 아니었다. 그러한 결정을 한 당시의 심판위원회가 그 쟁점을 어떻게 다룰지를 제시하는 정도로 이해되기 때문이다.

그런데 2015년 Browning Ferris(Cal.) 결정은 결정문에서 1982년 Browning Ferris(Penn.)의 결정과 그 결정을 인용한 다른 결정들까지 공식적으로 폐기한다고 명시했기 때문에 논쟁이 격렬해진 면이 있다. 법적으로 행정위원회의 심판 결과는 법원의 판결과 달리 선례구속성이 인정되지 않는다. 즉, 앞선 결정의 해석론이 아무리 오랜 기간 인용되고 이후 사례에 적용되었더라도 동일 유사한 쟁점의 후속 사안에서 필요하다고 판단된 경우에는 그 해석론을 적용하지 않아도 되는 것이다. 따라서 특정 사안을 다루면서 유사한 쟁점을 다룬 선행 결정을 공식적으로 폐기하는 선언은 상징적 의미만 갖는다고 할 수 있다. 그러나 선행 결정의 폐기 선언이 노사관계 실무와 당사자들에게 현실적인 영향력을 갖는 것은 부인할 수 없기 때문에 사용자단체들은 강력히 반발하면서 구체적인 대응 전략을 수립하고 실행하였다. 그 성과가 트럼프 정부에서 있었던 2020년 제정 시행령이었다고 할 수 있다.[49]

2020년 시행령 내용은 1982년 Browning Ferris 결정의 기준을 명시하여 공동사용자 지위를 결정할 때는 해당 사용자가 근로자의 고용관계에 대하여 직접적이고 실제적인 통제권을 갖고 있는지뿐 아니라 실제로 행사하였는지도 판단한다. 그러면서 임금, 부가급여, 근로시간, 채용, 해고, 징계, 감독(supervision) 및 지시(direction)의 여덟 가지 고용관계 핵심사항을 명시하고 각 사항별로 '직접적이고 직속적인 통제권direct and immediate control' 행사로 해석되는 경우와 그렇지 되지 않은 경우를 명시하였다.[50] 이는 개별 사안을 다루는 절차에서 심판위원회의 해석 재량을 제한하는 효과를 의도한 것이다.

2021년 임기를 시작한 바이든 정부는 노동정책을 트럼프 정부 이전으로 되돌린다는 목표하에 여러 가지 정책을 시행했다. 대표적으로, 트럼부 정부 때

---

49) 29 C.F.R §103.40(Subpart D) - Joint Employers(2020).
50) https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-B/chapter-I/part-103/subpart-D

현저하게 좁혀진 「공정근로기준법」 시행령의 공동고용관계(joint employment) 규정을 2021년 7월[51]에 폐지하였고, 이어서 2023년 8월에는 교섭대표 선출 절차에서 근로자의 수권카드(authorization card)의 증거력에 관한 시행령을 개정하였다.[52] 이런 맥락에 「연방노동관계법 시행령」 논의도 포함되어 있었다. 연방노동위원회는 법무총장(General Counse)의 제안과 심판위원회 논의를 거쳐서 공동사용자 지위에 관한 시행령 개정안을 만들었고 2022년 9월 7일에 관보에 게재하여 11월 7일까지 3개월간의 의견청취 기간을 공고하였다. 2020년 시행령을 폐지하고 새로운 공동사용자 판단 기준을 명시함으로써 당사자의 장래 권리와 의무에 영향이 있는 사항에 대한 또 한 번의 시행령 제정이 있게 되었다. 이렇게 빈번한 입법 논쟁은 연방노동위원회의 시행령 제정사에서 매우 드문 사례이다.

2023년 개정이유서는 공동사용자 지위 결정의 기준 변경이 2015년 Browning-Ferris(Cal.) 결정의 내용을 수용하고 있음을 명시하고 있다. 즉, 공동사용자 지위 판단은 간접적이고 유보되어 있는 지휘통제권이면 충분하고 그 권한을 실제로 행사했는지는 결정적 기준이 아니라는 것이다. 2023년 10월 27일에 「공동사용자 지위 결정 기준」으로 관보에 게재되었으며 60일 후인 2023년 12월 6일부터 발효가 예정되어 있다.

사용자단체가 크게 반발하는 쟁점은 '간접적' 그리고 계약으로 '유보'된 통제권의 기준이다. 공동사용자 지위를 판단할 때 간접적이거나 또는 유보된 통제권의 기준을 인정하면, 프랜차이즈 사업자 관계까지 「연방노동관계법」의 단체교섭 관계와 부당노동행위 책임이 적용될 수 있다는 주장이다. 이러한 주장은 개정 시행령의 의견청취 기간 동안에도 가장 많이 접수된 반대의견이었다.

이에 대한 개정이유서의 답변은 연방노동위원회가 향후에 하나 이상의 법정 사용자가 존재할 수 있는 간접고용관계의 단체교섭 관계와 부당노동행위 책임을 어떻게 만들어 갈 것인지를 보여주고 있다.[53] 연방노동위원회

---

51) https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/30/2021-15316/rescission-of-joint-employer-status-under-the-fair-labor-standards-act-rule.

52) https://www.nlrb.gov/news-outreach/news-story/national-labor-relations-board-issues-final-rule-to-restore-fair-and.

53) "모든 프랜차이즈 사업자 관계가 당연히 공동사용자 지위로 결정되는 것은 아

가 공동사용자 지위 결정기준의 배경으로 밝힌 내용의 개략은 다음과 같다.

I. 개정 배경

A. 관련 법률

「연방노동관계법」 제2조(2)는 '사용자'란 '직접적으로 또는 간접적으로' 사용자의 대리인으로 행위하는 모든 자'를 포함한다고 한다. 다음으로(제2조(3), 「연방노동관계법」은, '근로자'는 법률이 명시적으로 달리 정하지 않은 한, 특정 사용자의 근로자로 한정되지 않으며 모든 근로자를 포함한다고 한다. 「연방노동관계법」 제7조는 근로자는 다음과 같은 권리를 갖는다고 정한다.

- 단체교섭, 상호부조 및 보장을 목적으로, 단결할 권리, 노동조합을 결성, 가입, 또는 지원할 권리, 스스로 선택한 대표를 통하여 단체로 교섭할 권리, 그 외의 단체행동에 참여할 권리, 모든 또는 여하한의 그런 활동에서 참여하지 않을 권리

제9조는 근로자가 단체교섭 대표를 원하는 경우 교섭대표 선거를 진행할 권한을 연방노동위원회에 부여한다. 제8조(5)는 그의 근로자들 교섭대표와 단체교섭을 거부하는 것을 사용자의 부당노동행위로 정한다. 그러나 「연방노동관계법」은 둘 이상의 법률상 사용자가 공동으로 고용한 법률상 근로자가 있는 상황을 구체적으로 다루지 않는다.(예를 들어, 공동사용자 정의에 관해 침묵한다.) 그러나 아래에서 다루듯이, 하나 이상의 주체가 특정 근로자 집단의 고용관계 핵심사항과 조건을 공유하거나 공동결정하는 경우를 결정하기 위하여 연방노동위원회는 법원의 인정을 받아 오랫동안 보통법상 대리 원칙을 적용해 왔다.

B. 「연방노동관계법」의 공동사용자 법리 발전

1) 2022년 9월 4일 NPRM에서 보다 충분히 정한 바와 같이, Boire v. Greyhound Corp., 376 U.S. 473, 481(1964) 판례(버스터미널 운영 회사와 청소용역 사업자 사이 관계에 관련한 교섭대표 사안)에서 연방대법원은 'Greyhound사가 공동사용자 자격이 있는 정도로 그 근로자들의 작업에 충분한 통제권을 보유했는지' 여부가 연방노동위원회가 결정해야 하는 '핵심적인 '사실 문제'였다고 설명하였다. 환송심에서 연방노동위원회는 Greyhound사와 청소용역 수급인은 해당 근로자들의 공동사용자라고 결정했는데, 그 이유는 고용관계의 핵심사항과 조건을 통제하는 그 사안들을 공유했거나 공동결정했다고 보았기 때문이었다. Greyhound Corp., 153 NLRB 1488, 1495(1965), enfd. 368 F.2d 776(5th Cir. 1966).

니다. 또한 사업주들 사이의 근로자 파견이나 인력공급 관계도 마찬가지이다. 지금까지 공동사용자 지위 결정은 기업의 사업모델과 관계없이 하나 이상의 사업자가 근로자 고용관계의 핵심사항과 조건에 통제권이 있는지 여부로 결정해 왔고 새로운 시행령하에서도 그럴 것이다."

2) 연방노동위원회의 Greyhound 결정 이후 거의 20년간, 위원회는 근로자의 작업과 그의 고용관계 사항 및 조건에 대한 통제권을 어떤 주체들이 특정 근로자의 공동사용자인지를 분석할 때, 결정적인 것으로 간주했었다. 전반적으로 이 기간부터 연방노동위원회 선례는 추정 공동사용자가 실제로 또는 직접적으로 통제했는지에 대한 입증을 요구하지 않았다. 이 기간 동안 연방노동위원회와 법원은 공동사용자 사안에서 유보된(reserved) 또는 간접(indirect) 통제의 존재를 기본적으로 신뢰하였다. 그리고 재심 법원들은 공동사용자 분석에서 위원회가 증명하는 유보 및 간접통제 형식을 전반적으로 지지했다.

3) NLRB v. Browning-Ferris Industries of Pennsylvania, Inc., 691 F.2d 1117, 1123(3d. Cir. 1982)에서 연방 제3항소법원은 노동위원회의 공동사용자 기준의 '공유 또는 공동결정' 공식을 승인하였다. 이후 노동위원회 결정은 지속적으로 그 공식에 따랐으며, 또한 노동위원회는 이전 노동위원회 결정이나 판결, 확립된 보통법상 대리원칙에서 명확한 근거가 결여되어 있다고 생각하는 새로운 요건을 부과하기 시작했다. 참조. TLI, Inc., 271 NLRB 798(1984); Laerco Transportation, 269 NLRB 324(1984). 특히, 그 결정들은 (1) 추정 공동사용자는 "통제권을 실제로 행사"할 것, (2) 그러한 통제권이 '직접적이고 직속적'일 것, 그리고 (3) 그 통제권이 '제한적이고 일상적(routine)'일 것을 요구하기 시작했다. 참조. AM Property Holding Corp., 350 NLRB 998, 999-1003 (2007), enfd. In relevant part sub nom. Service Employees International Union, Local 32BJ v. NLRB, 647 F.3d 435 (2d Cir.2011); Airbone Express, 338 NLRB 597 (2002); Flagstaff Medical Center, 357 NLRB 659, 666-667 (2011).

4) 2015년 연방노동위원회는 둘 이상의 사용자가, 법률 제2조(2)에 정한 바와 같이, 법률 제2조(3) 범위에 있는 특정 근로자의 공동사용자인지를 결정하면서 그 전통적이고 보통법에 기반한 기준을 복원하고 명확히 하였다. 참조. Browning-Ferris Industries of California, Inc., d/b/a. BFI Newby Island Recyclery, 362 NLRB 1599(2015)(BFI). 확립된 보통법상 대리 원칙에 따라서, 그리고 이전 위원회가 설명도 없이 설정하였던 통제권에 근거한 제한(restriction)을 거부하면서, 노동위원회는 공동사용자 지위를 분석할 때 근로자 고용관계의 핵심사항과 조건'에 대한 유보되고 간접적인 통제권에 대한 증거를 고려할 것이라고 선언하였다. BFI는 컬럼비아 특별구 연방항소법원에 재심이 계류 중이었고, 노동위원회 구성 변경이 이루어진 동안에 이견이 있던 위원회(a divided Board)는 BFI에서 심각하게 이탈하는 공동사용자 기준을 설정할 목적으로 시행령 개정안 공고(notice of proposed rulemaking)를 하였다. 그 의견청취 기간 동안, 컬럼비아 특별구 항소법원은 Browning-Ferris Industries of California, Inc., v. NLRB, 911 F.3d 1195, 1222(D.C. Cir. 2018)를 판결하였는데, 공동사용자 분석에서 유보된 통제권한과 간접 통제권이 관련 요소가 될 수 있다는 노동위원회의 결정은 보통법에 완전히 부합하는 것이라고 확인하였고 새로운 기준을 개선하라며 그 사안을 위원회로 환송하였다.

5) 2020년 2월 26일에, 위원회는 공동사용자 기준을 좁힌 통제권 기반 제한을 다시 도입하는 최종 시행령을 공포하였다. 콜럼비아 특구 항소법원의 BFI v. NLRB 판결에 비추어, 위원회는 고용관계 핵심사항과 조건에 대한 간접적이고 유보된 통제권의 증거 '요소'에 대한 시행령안을 수정하였지만, 그러한 간접적 혹은 유보된 통제권은 또한 그 주체가 고용관계의 핵심사항과 조건에 대한 직접적이고 직속적인 통제권을 보유하거나 행사한다는 증거를 '보충하고 보강하는' 증거인 정도까지만이다. 또한 '다른 사용자의 근로자 고용관계 핵심사항과 조건을 공유하거나 공동결정'하는 당사자가 그 근로자들과 고용관계에 관한 사항들에 유의미하게 영향을 준다는 것에 대한 확인을 보장할 수 있을 정도로, 그들의 고용관계에서 하나 이상의 핵심사항이나 조건에 대해 실질적이고 직접적이며 직속적인 통제권을 가지고 행사했다는 것을 요구한다. 결국 그 시행령은 '실질적'이며 직접적이고 직속적인 통제권이란 다른 사용자의 근로자 고용관계 핵심사항과 조건에 정기적 또는 지속적이고 결과적인 영향을 주는 것이라고 정의하고, '실질적'이란 간헐적이고, 단절적 또는 사소한(de minimis basis) 수준으로 행사된 것은 배제한다는 의미라고 하였다. 고용관계의 핵심사항과 조건 목록을 한정적으로 열거하였는데, 그 구성은 임금, 부가급여, 노동시간, 채용, 해고, 징계, 감독 및 명령이고, 일부 사례를 다루었는데 그 목록에 있는 각 사항이나 조건에 대한 직접적이고 직속적인 수준이 될 것과 안 될 것이었다.

C. Notice of Proposed Rulemaking on Joint-Employer Standard

2022년 9월, 위원회는 새로운 공동사용자 NPRM을 발표하였다. 87 FR 54641, 54663(September 7, 2022). 개정 시행령안 공고에서 위원회는 공동사용자 법리의 최근 전개과정을 상세히 적었다. 위원회는 2020년 시행령이 위원회가 공동사용자 원리를 시행령 제정을 통해서 다룬 첫 번째 사례라는 것에 주목했다. 2020년 시행령은 보통법을 불필요하게 좁히는 통제권 기반 제한과 연방노동법의 목적을 훼손할 위험이 있는 내용을 포함하였다.

D. 관련 보통법(common law) 원칙

1) 위원회는 2020년 시행령이 취소되어야 한다고 결정했는데, 그 이유는 법률이 채택해서 연방노동법에 포함된 보통법의 대리 원칙에 반하며, 따라서 연방노동법 해석에 허용되지 않기 때문이다. 우리는 2020년 시행령이 취소되어야 한다고 믿지만, 우리는 그 시행령이 유효했었을지라도 연방노동법의 정책을 충분히 도모하는 데 실패했을 것으로 생각한다. 법률상의 '사용자'와 '근로자'는 보통법상의 의미를 갖고 있으며, 따라서 보통법이 위원회의 공동사용자 분석을 통제한다는 것은 잘 확립된 것이다. 참조. BFI v. NLRB, 911 F.3d at 1207-1208. 시행령 개정안 전문에서, 위원회는 (위 컬럼비아 항소법원 판결을 인용) "연방의회는 노동위원회가 아니라 법원이 보통법상의 '사용자' 범위를 결정"하도록 하며, 보통법은 사법부에 의해 정해지며, 위원회가 책임지는 어느 사업자가 다른 사용자의 근로자에 대한 공동사용자인가 하는 질문인 '정책 전문성'의 경계를 정한다고 하였다. 따라서, 연방노동법하

에서 공동사용자 지위 성립에 충분할 통제권의 형태를 정할 때, 노동위원회는 보통법을 적용하는 판사들이 우선적으로 형성한 관련 원칙과 학술논문, 보통법 판결의 리스테이트먼트 등의 관련 이차문헌을 포함하여 법원 판결에서 그 지침을 찾는다. 그 이차문헌들은 연방의회가 연방노동법을 제정하고 개정했던 1935년과 1947년 시점에 '확립'된 보통법 정의에 '처음으로 최우선으로' 중점을 두고 있다.

2) 제출된 의견을 고려한 이후, 위원회는 2020년 시행령에 반영된 '통제권을 실제로 행사해야 한다'라는 요건은 보통법의 대리 원칙에 반한다고 결정했는데, 그 대리 원칙은 연방노동법하에 공동사용자 기준을 통제해야 하며, 위원회는 그러한 요건을 채택할 법률상 권한이 없기 때문이다. 나아가, 위원회는 연방노동법의 해석을 통제하는 보통법 원칙에 따라, 고용관계의 핵심사항과 조건을 통제할 추정 공동사용자의 권한의 존재에 결정적 무게를 부여했다. 즉 그러한 통제권이 행사되었는지 아닌지 여부, 중개인을 통하는 것과 같은, 그러한 통제권이 직접인지 간접적인지 여부와 관계없다는 것이다.

2. 공동사용자의 유보된 통제권 논의

가. 보통법 연원

1935년 연방노동법 제정 이전에 오랫동안, 연방대법원은 사용자가 자신의 사업에서 행해져야 할 방식, 달성되어야 할 결과, 또는 해야 할 것뿐 아니라 하지 말아야 할 것을 명령하는 권리를 보유하는 경우에는 언제나 주종관계(master-servant relations)가 존재한다는 보통법 규칙을 인정하고 적용했다.[54] 1872년 판결에서 연방대법원은 기업이 자신이 고용한 근로자의 노무수행에 대해 계약적으로 유보된 통제권을 가졌다고 결정한 근거로, 해당 근로자가 열차 운전을 하는 데 있어 어떤 경로를 택해야 할지 지침을 주거나, 운행 속도를 정했던 사실을 제시했다. 이 같은 결론에 이르면서 연방대법원은 당사자 사이의 계약에만 근거하였고 그 기업이 실제로 그러한 통제권을 행사하였는지 어떻게 행사하였는지를 논하지 않았다. 달리 말해서, 대법원은 통제권이 행사되었는지 여부나 행사 방법에 상관없이, 계약적으로 유보된 통제권에 근거하여 보통법상의 사용자-근로자 관계를 결정하였다.[55]

54) Singer Mfg. Co. v. Rahn, 132 U.S. 518, 523(1889). (Railroad Co. v. Hanning, 82 U.S. 649, 657(1872)를 인용함.

1945년 컬럼비아 특구 항소법원은 독립수급인에서 근로자를 구별하면서, 가장 중요한 것은 통제 또는 감독 그 자체가 아니라, 통제할 권리라고 하였다.[56]

20세기 초반, 이차문헌들 역시 통제권이 성립시키는 보통법상 사용자-근로자관계의 존재는, 그 통제권을 행하였는지 또는 어떻게 행사하였는지에 관계없는, 보통법 원칙에서 도출한다. 예를 들어, 1922년, American Law Report 주석은 다음과 같은 내용을 기본원리로 설명한다.[57] 그에 따르면, 고용된 자와 사용자 사이에 관계의 본질을 밝히는 모든 사례에서, 결정되어야 할 핵심 질문은 사용자가 실제로 노동의 상세한 사항에 대해 실제로 통제권을 행사했는지 여부가 아니라, 그가 그러한 통제권을 갖고 있었는지 여부라고 하였다.

그리고 1933년에 출판된 Agency Restatement 제1판은 '주인(master)'과 '하인(servant)'을 다음과 같이 정하였다.[58] 첫째, 주인은 자신의 일에서 노무를 수행하도록 다른 사람을 고용하고, 그 노무의 수행에서 그 사람의 물리적 행위를 통제하거나 통제할 권리를 가진 본인(principal)이다. 둘째, 하인은 주인의 일에서 노무를 수행하도록 고용되고, 노무 수행에서 그의 물리적 행위가 주인의 통제권에 종속되어 있는 자이다. 또한 1936년과 1948년 사이에 출판된 American Jurispurdunce 제1판[59]은 사용자-근로자 관계의 실제 핵심요소는 통제권, 즉 일방 당사자인 주인이 다른 당사자인 하인이 어떠한 일을 어떻게 해야 하는지 명령할 권리라고 하였다.

---

55) Chicago Rock Island & Pac. Ry. Co. v. Bond, 240 U.S. 449, 456(1916).

56) Grace v. Maqruder, 148 F.2d 679, 681(D.C. Cir. 1945).(Grace는 자신이 Maqruder사의 근로자가 아니므로 원천징수한 사회보장세를 반환하라고 주장. Grace는Maqruder사이 석탄을 판매하는 외판원이었음. 사용자의 직접적 지휘감독이 없었다고 주장).

57) General discussion of the relationship of employer and independent contractor, 19 A.L.R. 226 at sec. 7 & fn.1(1922).

58) Restatement(First) of Agency sec. 2(AM. Law Inst. 1933).

59) 35 AM. JUR. Master and Servant sec. 3(1st ed. 1941).

나. 연방노동위원회의 판단

연방노동위원회는 법원과 협의절차를 거치면서 연방의회가 1935년 NLRA를 제정하고 1947년 Taft-Hartley 개정을 하였을 때, 노무가 수행되는 조건과 상세한 내용을 통제하는 추정 사용자의 유보된 권한의 존재는 그 통제가 실제로 어떤 방식으로 행사되었는지 또는 행사되었는지 여부에 관계없이 보통법상 사용자-근로자 관계를 성립하기에 충분했다고 결정했다.

1947년부터 오늘날까지 셀 수 없이 많은 판례와 권위 있는 이차문헌들이 검토한 보통법상 사용자-근로자 관계는 추정 사용자의 통제권을 최우선으로 계속해서 강조해 왔는데, 그 통제권이 행사되었는지 또는 어떤 방식으로 행사되었는지는 관계가 없었다. 예를 들어, 2014년, 캘리포니아주 대법원은 '보통법하에서 중요한 것은 채용인이 그 권리를 얼마나 행사하였는지가 아니라, 어느 정도의 권리를 보유하였는지'라고 확인하였다.[60] 위에서 언급했듯, *Agency Restatement* 제2판은 통제권에 대한 제1판의 강조를 그대로 따랐다. *Corpus Juris Secundum*은 '근로자 또는 하인은 그 물리적 행위가 주인에 의해 통제되거나 그 통제권에 종속되는 대리인(agent)의 한 형식인데, 그 하인의 물리적 행위를 통제하거나 통제할 권리를 가진 자, 즉 그 하인의 본인(principal)을 주인(master)이라고 한다'라고 설시한다. 그리고 *American Juriprudence* 제2판은 '고용관계의 본인 여부 검증은 원하는 결과를 달성하는 수단과 방법을 통제할 권리를 가졌는지 여부이다'라고 한다. 여러 판례와 이차문헌을 검토한 후에 위원회는 컬럼비아 지역 항소법원 판결 내용에 동의한다. 1935년과 1947년에 유효했던 보통법 원칙은 오늘날에도 여전히 유효한 보통법 원칙이다. 또한 위원회는 위에서 상세히 적은 바와 같이, 이 관점이 위원회가 TLI와 Laerco 결정 및 그 후속 결정들에서 추가적인 통제권 관련 제한을 부과하기 시작하기 이전, Greyhound 결정 이후 기간에 유보된 통제권에 대한 위원회의 결정과 일치한다는 것에 주목한다.

1984년 TLI 결정의 사실관계를 보면, TLI사는 고용사업주로서 사용사업주인 Crown사와 근로자파견 계약을 맺고 화물트럭 기사인 근로자를 Crown

60) Ayala v. Antelope Valley Newspapers, Inc., 327 P3d 165, 169, 172(Cal.2014) 참조.

사에 공급하였다. 사용사업주는 근로자들의 노동조합 활동을 이유로 TLI사와의 계약 내용을 변경하였고, 이에 따라 TLI사는 일부 고용조건을 변경하고 일부 근로자의 고용관계를 해지하였다. 이에 대하여 연방노동위원회는 사용사업주와 고용사업주는 연방노동법상 공동사용자의 지위이기 때문에 일방적으로 변경한 고용조건을 원래대로 회복해야 하며, 사용자들은 공동으로 노동조합과 회합하고 교섭해야 한다고 결정하였다.[61] 그런데 사업주들이 공동사용자 지위인가를 판단할 때, 1982년 Browning Ferris (Penn.) 결정을 인용하여, 근로자 고용관계의 핵심사항과 조건에 대해 직접적인 지휘통제권이 공유되었고, 그 통제권이 실제로 행사되었는지를 적용하였다.

1984년 Laerco 결정은 TLI 결정과 유사한 형태의 사안이다. 근로자공급업체인 CTL이 고용사업주로서 화물트럭 기사를 사용사업주인 Laerco사에 공급하는 관계였다. 그런데 심판위원회는 CTL사와 근로자 공급사가 근로자 고용관계의 핵심사항을 공유했거나 공동결정했다고 할 수 있을 정도로 CTL사가 실질적인 지휘통제권을 행사했다고 할 수 없다는 이유로 공동사용자가 아니라고 하였다.[62]

그러나 많은 사례의 사실들이 계약적으로 유보된 통제와 실제로 행사된 통제 사이에 구별을 요구하지 않으며, 지난 세기를 걸쳐서 많은 법원 판결과 다른 기관들은 그 구별을 명시적으로 포함하지 않는 보통법 검증기준을 명확히 밝혀왔다. 그러나 위원회는 계약상 유보된 추정 사용자의 통제권이 존재하는 경우에, 나아가 그 통제권의 직접적이고 직속적인 행사가 보통법상 사용자-근로자 관계 수립을 위해 필수적이라는 전제를 직접적으로 지지하는 어떠한 보통법 사법 판결이나 다른 보통법 권원을 알지 못한다. 그러한 이유로 노동위원회는 지배적인 보통법의 대리 원칙에 비추어, 어떤 주체가 다른 주체의 근로자에 대해 공동사용자라고 설정하기 위하여 직접적이고 직속적인 통제의 실제 행사 입증을 요구할 법적 권한이 없다고 판단한다. 정책상 어떤 경우에도 그렇게 하지 않을 것이다.

반대의견은 다음과 같이 비판한다. 근로자와 독립수급인 사이의 구별을

---

61) TLI, Inc., 271 NLRB 798(1984); TLI., Inc. v. NLRB, 772 F.2d 896(3d Cir. 1985).

62) Laerco Transp. & Warehouse, 269 NLRB 324(1984).

검증하는 기초에서 관련 보통법 원칙에 대한 권위를 구하고, 독립수급인 권한에서 파생한 보통법 원칙에 비추어 다른 연방법률하에 공동사용자 쟁점을 검토하는 사법 판결에 충분히 주목하지 않았다고 비판한다. 첫 번째 비판을 뒷받침하기 위하여, 반대 견해는 2018년 연방법원 판결에서 법원이 공동사용자와 독립수급인 판단기준이 '가시적으로 동일하다(virtually identicval)'는 한 당사자의 주장을 법원이 배척하였던 부분을 선택적으로 인용하였다.[63] 법원이 했던 것과 같이, 근로자 또는 독립수급인 결정을 안내하는 여러 요소들, 독립수급인 결정을 다루고 있는 Darden 판례[64]와 Reid 판례[65] 같은 1차 사법판단, 2차 개요서, 보고서 및 보통법상 대리 주석서에 명시한 것과 같이, 어떤 당사자의 근로자임이 명확한 노동자가 관련한 공동사용자 문제에 대하여 의미 있는 빛을 비추지는 않을 것이라고 인정한다. 그럼에도 두 가지 모두 보통법상 주종관계의 존재를 궁극적으로 입증하며, 주종관계 성립의 중심은 -독립수급인 탐구 목적인지 혹은 공동사용자 탐구 목적인지 여부- 추정사용자의 통제권 성격과 범위라고 한 법원에 위원회는 동의한다. 시행령안은, 시행령 제103.40(a)에 정한 경계(threshold)로서 추정 사용자와 특정 근로자 사이에 보통법상 사용자-근로자 관계가 존재하는지 여부를 결정하기 위한 독립수급인 지위 결정에 포함된, 보통법 자료들에서 지침을 구하고 있는 2018년 Browning Ferris 판례에 부합한다.

3. 중개자를 통해 행사한 통제를 포함하는 간접통제

위원회는 다른 사용자의 근로자 고용관계의 핵심사항과 조건에 대한 통제권을, 직접적이든 아니면 중개인을 통한 것과 같이 간접적이든 간에, 사실상 행사했다는 증거는 공동사용자 관계의 존재를 성립하게 하기에 충분하다고 결정하였다. 2018년 컬럼비아 법원이 승인한 바와 같이, 보통법은 고용관계의 핵심사항과 조건을 결정할 때 관련한 역할을 한 간접적 통제 방식

63) Browning Ferris Indus. of Cal. Inc. v. NLRB, 911 F.3d 1195, 1213-1215(D.C. 2018).
64) Nationwide Mutual Insurance Co. v. Darden, 503 U.S. 318, 322-324(1992).
65) Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 751(1989).

을 고려한다. 또한 법원은 연방노동법 제2조(2)에 정한 '사용자'는 문맥적으로, 법률이 사용자 지위의 모든 증명 가능한 지표를 고려하는 것이라고 하면서, 따라서 연방노동법은 명시적으로 사용자를 대신하여 '간접적으로' 행위하는 대리인도 사용자로 간주될 수 있다고 한 것이라고 하였다. 이와 같이 여러 판례와 주요 문헌들은 중개인을 통해서 행사되는 통제권을 포함하는 간접 통제가 고용관계의 존재를 입증할 수 있다고 한다. *Restatement (Second) of Agency*는 두 번째 당사자가 근로자를 직접적으로 통제하면서 사용자의 통제권이 간접적으로 행사되는 사안의 경우에 통제 또는 통제권은 주종관계의 성립을 훼손할 수 있다고 하면서, 명시적으로 간접 통제의 중요성을 승인하였다. 이와 같이 보통법은 주종관계의 성립을 회피할 목적으로 활용되는 중개인 또는 통제되는 제3자의 사용을 허용한 적이 없다. 마찬가지로, 제4항소법원도 한 당사자가 다른 사용자의 근로자에 대해 공동사용자라고 하였는데, 해당 근로자의 직접 사용자가 행했던 징계와 해고 결정을 권유함으로써 그 근로자의 징계와 해고에 대한 간접 통제를 행사했다는 이유였다.[66]

이와 같은 오랜 보통법 원칙을 수용하여, 연방노동위원회는 추정 공동사용자가 다른 사용자의 근로자 고용관계의 핵심사항과 조건 하나 이상에 대한 간접 통제권을 행사했음을 증명하는 증거는 공동사용자 관계를 성립시킬 수 있다고 결정한다. 예를 들어, 공동사용자가 업무배분과 작업지침에 대하여 다른 사용자의 관리자와 협의하고 근로자의 개별 업무수행 수단과 구체적인 방식에 대해 자세하고 지속적인 감시를 한 것은 공동사용자 관계를 성립시키기에 충분한 정도로서 고용관계의 핵심사항과 조건에 대한 간접통제를 입증할 것이다.[67]

개정 시행령이 정한 고용관계의 핵심사항과 조건은 열거적인 것이 아니라 예시적인 것이다. 연방노동위원회는 공동사용자 지위 판단에서 '핵심적'

---

66) Butler v. Drive Automotive Indus. of Amer., Inc., 793 F.3d 404, 415(4th Cir. 2015).

67) Cognizant Technology Solutions U.S. Corp. & Google LLC, 372 NLRB No. 108, slip op. at 1(2023) 참조(2020년 시행령에 따른 직접적이고 직속적 통제로 간주되는, Cognizant사의 중간 근로자를 통한 Google사의 지휘감독권 행사에 부분적으로 근거하여 공동사용자 관계 인정.)

인 것으로 간주될 수 있는 고용관계의 핵심사항과 조건을 7개 범주로 나누었다.

(1) 임금, 부가급여 및 기타 보수
(2) 근로시간과 작업일정
(3) 수행될 업무의 배분
(4) 그 업무수행에 대한 감독
(5) 업무수행의 방식, 수단 및 방법을 통제하는 작업규칙과 지침, 징계사유
(6) 채용과 해고를 포함하여, 고용기간
(7) 근로자의 안전과 건강에 관련된 작업조건

이 범주에 속하는 하나 이상의 사항에 대하여 실제로 행사하진 않았지만 통제권을 유보하고 있거나 중개인을 통하여 간접적으로 통제를 행한 사업주들은 공동사용자 지위가 성립될 것이다. 공동사용자는 자신이 통제권을 보유하고 있거나 통제권을 행사한 고용관계 사항이나 조건(이 경우에는 개정 시행령이 정한 고용관계의 핵심사항이나 조건에 해당하는지는 관계가 없음)에 관하여 그 근로자들의 교섭대표와 단체교섭해야 한다.

4. 연방노동위원회의 공동사용자 지위 해석 변화

공동사용자 지위 결정과 관련하여 연방노동위원회의 해석 변화는 다음과 같이 요약될 수 있다.

통제권 수준	결정사례 및 시행령
직접적이고 직속적인 통제권 보유와 행사 여부	Browning Ferris(Penn.), 259 NLRB 60(1981) NLRB v. Browning Ferris Industries, 691 F.2d 1117(3rd Cir. 1982)
	Laerco Transp. & Warehouse, 269 NLRB 324(1984)
	TLI, Inc., 271 NLRB 798(1984) TLI., Inc. v. NLRB, 772 F.2d 896(3d Cir. 1985)
	29 CFR 103.40(Subpart D) -- Joint employers.(2020)
간접적이고 중개인 수준의 통제권; 통제권의 보유 여부	Browning Ferris Indus. of Cal., Inc., 362 NLRB 186(2015) Browning Ferris Indus. of Cal. Inc. v. NLRB, 911 F.3d 1195 (D.C. 2018)
	29 CFR 103.40(Subpart E) - Joint employers.(2023)

제4절 파견용역 고용관계의 공동사용자

사용사업주의 사업장에서 근로하는 파견(도급) 근로자와 직접고용 근로자로 구성된 교섭단위는 사실상 다수사용자 교섭단위가 아니다. 그 사업장에서 모든 근로자는 공동고용이든, 단독고용이든, 사용사업주에게 고용된 것이며, 모든 근로자들의 노무가 사용사업주를 위해 수행되기 때문이다.[68]

사용사업자인 Oakwood는 근로자파견 사업자인 N&W사로부터 일반직 근로자를 공급받았다. 이들은 요양원 내에서 필요한 통상적인 업무를 직접고용 근로자들과 함께 수행하였다. Oakwood 요양원은 파견용역근로자의 작업을 직접 지휘감독했다. 임금과 부가급여도 N&W사와 함께 결정하였다.[69]

1. 사용사업주/원청의 단체교섭 관련 의무

가. 실체적 의무

단체교섭에서 공동사용자 지위가 인정되면 사용사업주는 노동조합과 근로자에게 단체교섭과 관련한 정보를 제공하거나 단체교섭장에 참석할 의무를 부담한다. 단체협약이 유효한 중에 고용사업주와 근로자파견(도급) 계약을 해지하고 다른 기업으로 변경하고자 하는 사용사업주는 그 결정에 관해 고용사업주의 노동조합과 교섭할 의무가 있다. 도급계약 해지 결정으로 파견(도급) 근로자들의 근로조건이 변경되는 결과에 관한 협의이며 또한 고용사업주와 노동조합이 충분한 교섭할 수 있도록 시간을 주는 사전통지 의무도 부담한다.[70]

---

68) M. B. Sturgis, Inc., 331 NLRB 173(2000); Professional Facilities Management, Inc., 332 NLRB 40(2000). 김미영(2010), 「미국 연방노동법의 공동고용 원리에 관한 연구」, 『노동법학』 33, 한국노동법학회, p.151.

69) Oakwood Care Center, 343 NLRB 659(2004)

70) Parma Indus., Inc., 292 NLRB 90, 91(1988); Service Employees Union, Local

나. 절차적 의무

공동사용자 지위에 있는 사용사업주가 그 의무를 위반하면 연방노동위원회는 이행명령을 할 수 있다. 단체교섭 참석명령, 정보제공명령, 사전통지명령 등. 그 명령을 준수하지 않으면 형사처벌 대상이 된다. 사전통지의무 위반에 대해서는 파견(도급) 근로자들에 대한 소급임금(backpay) 지급명령 : 일시해고 이후 사전통지일 또는 교섭이 실시되지 못한 날 사이 기간. 그러나 근로자 파견(도급)계약을 계속 유지하거나, 파견(도급) 근로자를 복직시키는 명령은 할 수 없다.

2. 부당노동행위 책임

공동사용자 지위가 인정되면 그 부당노동행위의 책임도 함께 부담한다. 그러나 공동사용자 지위에 있는 파견용역 관계의 사업주라도 상대방 사용자의 부당노동행위를 연대책임으로 부담하는 것은 아니다. 예외적으로, 유인, 방조, 공모 등의 방법으로 상대방의 부당노동행위를 알았거나, 사업관계상 알 수 있었을 때는 공동으로 책임을 부담한다. 부당노동행위의 직접행위자가 아닌 사용자는 자신의 실질적인 권한 범위 내에 있는 사항에 대한 구제명령을 이행하면 된다.

원칙적으로 공동사용자는 자신이 직접 행한 부당노동행위에 대한 책임만 부담한다. 사용자들 사이에 공동사용자 관계가 인정된다고 해도 차별적 사유에 의한 부당노동행위 책임은 다른 사용자가 위법한 동기로 근로자에게 적대적인 처우를 하였다는 것을 알았거나 알 수 있었던 경우, 그리고 반대하거나 가능한 범위에서 그 처우를 방지하려고 하지 않고 소극적으로 동의한 경우에 공동책임을 진다.[71] 다만, 상대방 사용자가 근로자에게 행한 차별적인 처우를 몰랐거나 알 수 없는 경우였다면 책임을 공동으로 부담하지 않는다.

87(Trinity Maintenance), 312 NLRB 715(1993); Mobil Oil Corp., 219 NLRB 511, 512(1975). 김미영(2010), 앞의 책, p.150.

71) 이정 외(2012), 『고용관계 다변화 실태와 법적규율 필요성 연구』, 고용노동부, p.148.

사용사업주의 관리자가 해당 근로자에게 구체적인 작업을 배정하였고 그 징계와 해고에 관해서 고용사업주에게 권고할 수 있는 권한 행사. 근로자의 핵심적 고용관계 내용과 조건을 공동결정한 것이므로 공동사용자의 지위를 인정하였다. 사용사업주가 해당 근로자를 해고하는 사유가 사업장에서 노동조합 활동을 한 것이라는 위법한 동기를 고용사업주에게 명시적 · 묵시적으로 고지하지 않았기 때문에 고용사업주는 그 부당노동행위 책임을 부담하지 않는다.[72] 사용사업주와 고용사업주가 공동사용자 지위에 있지 않더라도, 근로자와 고용사업주 사이 고용관계상 지위에 영향을 주는 고의적이고 위법한 행위에 대하여 사용사업주는 부당노동행위 책임을 질 수 있다. 사용사업주에게 소급임금 지급을 명령하면서 사용사업주의 위법한 동기를 알지 못하고 근로자를 사용사업주의 사업장에서 배제하는 것에 동의한 고용사업주는 책임이 없다.[73]

제5절 소 결

공동사용자 법리는 「공정근로기준법」의 최장근로시간과 최저임금의 수규자로서 사용자 지위에 관한 원리로 출발했지만, 세법이나 「사회보장법」 영역에도 널리 채택되고 있다. 이런 이유로 공동사용자 원리가 적용되는 사업주 계약관계는 상당히 넓은 편이며, 사내도급과 파견근로 관계가 가장 전형적이긴 하지만 모자기업, 프랜차이즈, 사외도급, 심지어 건물임대차 관계인 경우에도 적용된 사례가 있다. 사업주 사이의 계약관계가 아니라, 근로자에 관한 핵심적 고용조건을 결정하거나 실질적으로 지배했는지를 기준으로 하기 때문인데, 공동사용자 관계가 성립하면, 사용사업주와 고용사업주는 근로자에 대해 연대하여 노동법상 책임(joint and several liability)을 부담한다. 즉, 한 사용자가 법률의 최저임금과 연장근로수당을 근로자에게 지급하였다면, 나머지 다른 사용자는 그 지급의무를 면하게 된다.

---

72) Capitol EMI Music, 311 NLRB 997(1993). 김미영(2010), 앞의 책, p.151.
73) Flav-O-Rich Inc., 309 NLRB 262(1992). 김미영(2010), 앞의 책, p.153.

제 4 장
요약 및 결론

노동법의 목적은 흔히 “근로자 보호”로 이해되고 있는데 이를 법적으로 표현하면 근로자에게 노동조건 및 사회보장급여와 관련된 권리, 권한, 혜택(법적 보호가치 있는 이익)을 부여한다는 것이다. 그리고 이는 권리에 대응하는 의무를 이행하고, 권한에 조응하는 책임을 부담하며,[74] 혜택을 제공할 상대방의 존재를 전제로 한다. 그렇기에 현행 노동관계법은 사용자를 그러한 의무, 책임, 혜택 제공의 주체로 삼아 근로자 보호를 실현하고 있다.

따라서 전통적 · 표준적 근로자가 아닌 노무제공자에게 여러 노동관계법상 권리 등을 부여한다고 하더라도, 막상 그것을 관철하는 데 있어 실질적으로 가장 중요한 역할을 하는 사용자가 확정되지 않거나, 사용자로 주장되는 이가 그러한 사실을 부인하거나, 최종적으로 문제를 해결해야 하는 법원이 그러한 판단을 할 수 있는 객관적 기준을 갖고 있지 않다면 ‘노동법의 인적 적용범위 확대’의 실익은 전혀 없다고 말할 수 있다. 예컨대 「근로기준법」상 근로자로는 볼 수 없는 ‘특고’, 프리랜서, 플랫폼종사자 등으로 (각각) 조직되어 설립신고까지 마친 노동조합이 다수 존재하나, 그들로부터 단체교섭을 요구받은 이가 사용자임을 부인하여 실제 단체교섭에 이르지 못하는 경우가 빈번히 발생하고 있다.[75]

---

74) “법의 정신은 권한과 책임을 조응시키는 데 있다.”, 박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, p.7.

75) 박은정(2020), 「지금 왜 다시 사용자인가? 플랫폼 노동관계에서 사용자 찾기」, 『노동법포럼』 31, 노동법이론실무학회, pp.215~252.

개별 노동법 규범의 다양한 목적에 따라 노동법의 주요 개념에 대한 정의와 범주를 달리 결정하고자 하는 필자의 생각은 이 연구에서도 유효하다. 지난 연구에서 노무제공자가 갖는 총 네 가지 취약성과 두 가지의 속성을 개념화했고 상호관계를 밝혔다. 즉 ① 법적 인적 종속성(노동력 자체를 사용자의 지시 · 처분에 맡겨야 하는 법적 의무로부터 비롯되는 인격적 피지배 또는 민주성 결핍), ② 법적 경제적 종속성(약정한 기간 · 시간 동안 자신의 노동력을 독자적으로 사용해 경제적 이익 창출 금지), ③ 계약 교섭 및 계약 결과의 불공정을 야기하는 경제적 의존성(임노동을 통해 생계를 유지해야 하는 노무제공자의 사회경제 구조적 취약성), ④ 최소한의 인간존엄 및 생존을 위협하는 노동조건을 초래할 수 있는 경제적 의존성을 해소 또는 완화하는 것을 목적으로 하는 개별 법규범의 총합이다.[76] 네 가지 취약성에 더해 "조직적 종속성"(혹은 사업편입성)이라는 속성이 있고, 이는 사용자 측면(해당 노무제공자의 업무가 사용자 사업수행에 핵심적 · 상시적인지)과 노무제공자 측면(해당 업무가 시장에서 독립적으로 거래될 수 있는지, 즉 사업자성 유무)의 두 가지로 구별할 수 있는데, 이것의 존재는 각각 법적 인적 종속성과 경제적 의존성(계약조건의 불공정성)의 존재를 추정 · 징표한다.

이 연구는 이러한 개별적 · 구체적 취약성으로부터 도출되는 개별적 · 구체적 '이익'을 얻는 이가 사용자로서 해당 노동법상 권리에 대응하는 의무를 부담해야 한다는 원칙하에 사용자 개념 및 범위 문제에 접근하고자 한다. 즉 연구책임자의 선행연구가 '취약성' 개념을 분석 · 유형화하고 각 취약성과 개별 노동법 규범을 연계하였다면, 본 연구는 '이익' 개념을 분석 · 유형화하고 이를 선행연구에서 검토 · 제안된 '사업' 개념과 연동해, 다양한 맥락에서 등장하는 사용자 해당성, 사용자 범위의 획정, (확정된 사용자가 복수일 경우) 각 사용자에게 귀속되는 의무와 책임의 종류와 정도 문제를 판단할 객관적 기준을 개발하는 것을 본 연구와 후속연구의 궁극적 목적으로 삼는다.

다시 말해 본 연구와 후속연구는 다양한 취업형태하에 있는 노무제공자의 권리, 권한, 혜택에 대응하는 의무와 책임을 부담하는 사용자의 개념 · 범주를 분석하고 적용되는 법령과 법률관계의 특성에 따라 해당 '사용자'를 확

76) 남궁준(2021), 『취업형태 다변화와 노동법상 임금원칙의 확장성 검토』, 한국노동연구원 참조.

정하며 사용자가 복수일 경우 관련 의무 · 책임의 분담 및 귀속을 결정할 객관적 기준을 개발 · 제안하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 개별 사건에서 구체적으로 타당한 결론을 끌어내기 위한 목적과 수준에서 다루어졌던 사용자성에 대한 판례에 정합적인 논리를 제공하여 예측 가능성과 법적 안정성까지 확보하는 것을 목적으로 한다.

다만 본 연구는 이러한 이론 개발을 위한 전 단계 작업에 주력한다. 우선 본 연구의 문제의식을 명확히 하기 위해 노동관계의 유형을 체계화하는 것이 목적이다. 따라서 우선 먼저 확장된 사용자 범위를 반영하고 있는 현행 노동관계법령의 규정을 살펴본다. 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」은 파견근로자와 관련해 파견사업주에게 전적으로 귀속되었을 사용자의 의무와 책임 중 일부를 사용사업주에게 분배하고 있다. 「산업안전보건법」도 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위해 조치를 취해야 하고, 이와 연계해 산업재해 발생 건수 공표에 있어서도 해당 근로자를 포함시킨다. 「근로기준법」도 도급 사업에 대한 임금 지급 시 직상수급인의 귀책사유 존재를 전제로 한 연대책임, 이를 한층 더 확장 · 강화한 건설업에서의 책임, 「최저임금법」은 최저임금액에 미치지 못하는 임금 지급 시 도급인과 수급인의 연대책임을 규율하고 있다.

결국 우리의 개별적 「근로관계법」 · 「노동보호법」은 첫째, 법으로 인정한 파견근로관계의 경우에는 포괄적인 차원에서 복수의 사용자 존재를 전제하고 그 안에서 적정하게 사용자 책임을 재분배한다. 둘째, 기본적인 인권에 해당하는 근로자의 신체적 안전 · 건강과 같은 근로조건의 경우 그 확보에 있어 최적의 지위에 있는 주체에게 사용자 책임을 부과한다. 셋째, 위의 두 경우가 아니더라도, 예컨대 파견근로관계도 아니고 주요 근로계약조건의 하나인 임금에 해당하는 것이라도 그것의 현실적 보장을 위해 꼭 필요한 경우에는 예외적으로 입법을 통해 본래의 사용자를 넘어 그에 대한 책임을 (일부) 귀속시키고 있다는 것을 알 수 있다.

역사적으로 연방노동위원회 결정과 법원 판결이 공동사용자 지위 원칙을 형성한 것은 파견 및 용역고용의 단체교섭 관계를 규율하는 목적이었다. 이번에 개정된 「연방행정법규(시행령)」가 정한 고용관계의 핵심사항과 조건은 열거적인 것이 아니라 예시적인 것이다. 연방노동위원회는 공동사용자 지위 판단에서 '핵심적'인 것으로 간주될 수 있는 고용관계의 핵심사항과 조

건을 다음의 7개 범주로 나누었다. (1) 임금, 부가급여 및 기타 보수, (2) 근로시간과 작업일정, (3) 수행될 업무의 배분, (4) 그 업무수행에 대한 감독, (5) 업무수행의 방식, 수단 및 방법을 통제하는 작업규칙과 지침, 징계사유, (6) 채용과 해고를 포함하여, 고용기간, (7) 근로자의 안전과 건강에 관련된 작업조건. 이 범주에 속하는 하나 이상의 사항에 대하여 실제로 행사하진 않았지만 통제권을 유보하고 있거나 중개인을 통하여 간접적으로 통제를 행한 사업주들은 공동사용자 지위가 성립될 것이다. 공동사용자는 자신이 통제권을 보유하고 있거나 통제권을 행사한 고용관계 사항이나 조건(이 경우에는 개정 시행령이 정한 고용관계의 핵심사항이나 조건에 해당하는지는 관계가 없음)에 관하여 그 근로자들의 교섭대표와 단체교섭을 해야 한다.

노동법의 사명을 '이익이 있는 곳에 책임도 있다'는 원칙의 노동관계에서의 실현으로 보는 입장(강희원, 2011)이 폭넓게 받아들여지고 있고,[77] 이를 '사업 네트워크'(강주리, 2022) 등의 개념을 통해 사용자성 논의에서도 현대화하고자 하는 이론적 시도가 있는바,[78] 본 연구는 원칙적으로 이러한 문제의식에 동의하면서도 여기서의 '이익'의 개념을 명확히 정의하고 유형화하여 그 구체적 이익에 비례하는 사용자의 '책임'을 설정하고 부여하는 작업이 필요하다.

일단 사용자 개념을 파악할 때 명확한 출발점은 근로자와 근로계약을 체결한 타방 당사자이다. 이때 '이익'은 순수하게 법적인 이익으로서 사용자가 약정 기간 · 시간 동안 근로자의 노동력을 자신의 의지에 따라 배타적으로 사용할 수 있는 권한을 획득하는 것을 의미한다. 즉, 해당 이익의 구체적 · 경제적 가치를 검토할 필요 없이 근로계약을 체결하고 지시권을 행사하는 자가 사용자가 된다.

다음은 경제적 관점에서의 접근인데, 이익 개념을 검토할 때 노동법상 '사업' 개념도 함께 검토되어야 한다. 왜냐하면 해당 이익이 실현되는, 즉 의미 있는 경제적 가치를 창출하는 단위는 원칙적으로 사업, 즉 "하나의 사업

77) 강희원(2011), 「간접고용과 근로자의 보호 : 시민법적 계약형식과 노동법적 이념의 갈등」, 『경희법학』 46 (2), pp.9~64.
78) 강주리(2022), 「사업 네트워크와 사용자 책임」, 『노동법학』 81, 한국노동법학회, pp.1~39.

목적을 위하여 유기적으로 연결되어 있는 경제적 동일체"(박제성, 2021)로 보는 것이 가장 합리적일 것이기 때문이다. 다만 이 사업의 개념 범주는 해당 사건에 적용될 법령의 목적에 따라 가변적일 수 있어 구체적으로 검토해야 한다. 이러한 작업은 후속연구에 담고자 한다.

참고문헌

강주리(2019), 「미국 공정근로기준법의 제3자 규제구조」, 『사회법연구』 39, 한국사회법학회.

_____(2022), 「사업 네트워크와 사용자 책임」, 『노동법학』 81, 한국노동법학회.

강희원(2011), 「간접고용과 근로자의 보호 : 시민법적 계약형식과 노동법적 이념의 갈등」, 『경희법학』 46 (2), pp.9~64.

권오성(2022), 「'일하는 사람을 위한 기본법' 제정의 필요성」, 『노동법학』 81, 한국노동법학회.

김미영(2010), 「미국 연방노동법의 공동고용 원리에 관한 연구」, 『노동법학』 33, 한국노동법학회.

김주병(2019), 「직업안정법」을 통한 플랫폼노동중개의 규율 가능성과 과제」, 『노동법학』 70, 한국노동법학회.

남궁준(2021), 『취업형태 다변화와 노동법상 임금원칙의 확장성 검토』, 한국노동연구원.

노동법실무연구회(2020), 『근로기준법 주해 Ⅲ(제2판)』, 박영사.

박은정(2020), 「지금 왜 다시 사용자인가? 플랫폼 노동관계에서 사용자 찾기」, 『노동법포럼』 31, 노동법이론실무학회.

박종희(2011), 「한국의 비정규고용의 실태와 법률적 쟁점 : 비정규고용의 현황, 대응과정 및 향후 개선방안을 중심으로」, 『외법논집』 35 (4), 한국외국어대학교 법학연구소.

박제성(2022), 『동태적 사업 개념 : 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원.

이정 외(2012), 『고용관계 다변화 실태와 법적규율 필요성 연구』, 고용노동부.

임종률(2018), 노동법(제16판), 박영사.

한국노동연구원(2022), 『KLI 비정규직 노동통계』, 한국노동연구원.

Jeremias Prassl(2015), The Concept of the Employer, Oxford Monographs on Labour Law, Oxford University Press.

통계청, 한국종사상지위분류 개정 보도자료(2021. 12. 29).

https://www.federalregister.gov/documents/2020/01/16/2019-28343/joint-employer-status-under-the-fair-labor-standards-act.

https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/12/2021-04867/rescission-of-joint-employer-status-under-the-fair-labor-standards-ct-rule.

https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-B/chapter-I/part-103/subpart-D.

https://www.nlrb.gov/news-outreach/news-story/national-labor-relations-board-issues-final-rule-to-restore-fair-and.

◈ 執筆者

• 남궁준(한국노동연구원 연구위원)

취업형태 다변화와 노동법상 사용자 개념의 다원적 구성

▪ 발행연월일 | 2023년 12월 26일 인쇄
2023년 12월 29일 발행
▪ 발 행 인 | 허 재 준
▪ 발 행 처 | 한국노동연구원
3 0 1 4 7 세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 경제정책동
☎ 대표 (044) 287-6080 Fax (044) 287-6089
▪ 조판 · 인쇄 | 도서출판 창보 (02) 2272-6997
▪ 등 록 일 자 | 1988년 9월 13일
▪ 등 록 번 호 | 제13-155호

ⓒ 한국노동연구원 2023 정가 5,000원

ISBN 979-11-260-0700-4

KLI
한국노동연구원

한국노동연구원

30147 세종특별자치시 시청대로 370 경제정책동
TEL : 044-287-6083 http://www.kli.re.kr

OPEN 공공누리
출처표시 상업용금지 변경금지
공공저작물 자유이용허락

93000
9 791126 007004
ISBN 979-11-260-0700-4